

2026 年方鹏刑法私塾班



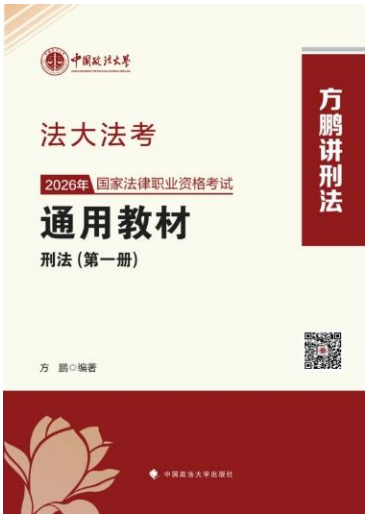
2026 年
《方鹏讲刑法》
带读讲义

编著+带读：方鹏 副教授

2026 年 1 月 31 日

2026 年法考刑法私塾课程
《方鹏讲刑法》带读





9.9元：15个晚上学透刑法



直播：cctalk"刑法学人方鹏"

《刑法主客一体班》

2026 方鹏刑法《主客一体班》

网络直播课程计划

cctalk“刑法学人方鹏”

报客观送主观，报主观送客观

客观主观一起学、一次过

阶段	课程		课时	时间 适时加课	课程简介	课程资料	
带读课：（基础阶段）	刑法基础课		16+（晚上+周末）	2016.1.30-2016.2	1. 刑法学习方法 2. 刑法思维及案件推理 3. 犯罪构成理论及实用 4. 总则考点 5. 核心罪名	私房讲义、教材：《方鹏讲刑法》-通用教材	
专题突破：（强化阶段）	《客观考点精析》		50+（每周一晚）	2026.2-7	疑难必考点各个击破（专题小灶班），讲全讲透；提炼、串讲、巩固高频考点 1. 分则全部罪名专题 2. 总则疑难必考点回顾 3. 刑罚论 4. 历年真题（分考点）	私房讲义、教材：《客观金题解析》、《主观一本通》	
	《主观专题与写作训练》				讲解、现场演示、习题演练、作业批改；记住套路、模板、关键词与采分点： 1. 答题方法论 2. 主观专题专讲专练 3. 主观题多观点题型 4. 主观题历年真题		
串讲、题海、考前急救包：（实战阶段+冲刺阶段+考前黄金预测）	客观	1. 考点串讲+经典真题	6+	2026.8	刑法 80 个考点全面串讲、回顾+经典真题示例	私房讲义	
		2. 重点法条带读	6+		重点法条专讲		
		3. 刑法客观金题 300 道	12+（周末）		高质量、大难度金题，畅游题海淬炼实力；黄金考点（道道经典，题题精选）		
		4. 背多分+押题 100 道	14+（七个早晚）		专项带背带练、大面积押中，物超所值		
		5. 客观考前三小时	3+（一晚）	2026.9	三小时浓缩精华（黄金考点预测）		
	主观	1. 主观题法条带读	6+	2026.8-10	重点法条专讲		
		2. 案例分析指导书精讲	3+		综合解题能力训练		
		3. 主观两天速成	8+		必考知识点回顾	《主观一本通》	
		4. 综合大案例训练+多观点题汇总	6+		道道经典：高质量、大难度、综合题全面演练	私房讲义	
		5. 主观背多分	14+（七个早晚）		带写带练、题题珠矶：大面积押中，物超所值		
		6. 主观考前三小时	3+（一晚）	2026.10	三小时浓缩精华（必考考点锦囊）		

学好真刑法，仗剑走天涯

2026方鹏刑法主客一体班

cctalk“刑法学人方鹏”

微博“刑法学人方鹏”

法考刑法 80 个考点

（★《刑法修正案（十一）、（十二）》修正之处）

	章节名		80 个考点
刑法总论	刑法概说		（1）**刑法解释**：扩大解释与类推解释，当然解释，体系解释；文理解释与目的解释；（2）罪刑法定原则；（3）空间效力，时间效力；（4）**犯罪构成理论**：客观不法-主观责任，先客观后主观，客观主观统一；（5）构成要件要素的分类
	客观不法		（6）危害行为，实行行为；（7）**不作为**；（8）**因果关系**
	主观责任	责任年龄	（9）**刑事责任年龄**★
		责任能力	（10）精神病，**原因自由行为**
		罪过	（11）故意的认识要素；（12）**故意，过失的认定**；（13）**事实认识错误**
	犯罪排除事由		（14）**正当防卫**，紧急避险，被害人承诺；（15）**违法性认识错误**，欠缺期待可能
	犯罪形态		（16）犯罪既遂，**犯罪中止**，犯罪未遂，犯罪预备；（17）未遂与不能犯
	共同犯罪		（18）**共同犯罪**：共同不法；共同犯罪成立条件，承继共犯，间接正犯，共犯从属说，教唆行为，欺诈教唆，中立帮助，共犯与身份，部分中止，共犯脱离，共犯认识错误，不作为与共犯
	单位犯罪		（19）单位犯罪
	罪数规则		（20）分则规定（法条竞合；结果加重犯；结合犯等 12 个规定）； （21）**想象竞合犯**；连续犯，**牵连犯**，**吸收犯**，**事后不可罚**
	刑罚体系		（22）禁止令，社区矫正；（23）**死刑**；（24）剥夺政治权利，没收财产（正当债务返还），犯罪物品处理；职业禁止令
	刑罚裁量		（25）**累犯**；（26）**自首**（坦白）；（27）立功；（28）**数罪并罚**
	刑罚执行		（29）**缓刑，减刑，假释**
	刑罚消灭		（30）**追诉时效**

方鹏刑法讲义

续表

刑法分论	分论概说	（31）**法条竞合**：四种法条竞合，与想象竞合的区别
	第 2 章危害公共安全罪	（32）公共安全的含义；（33）放火罪，投放危险物质罪，**以危险方法危害公共安全罪**；（34）**破坏公共设施犯罪**；（35）涉枪犯罪，恐怖犯罪；（36）**交通肇事罪**，危险驾驶罪；**妨害安全驾驶罪**★；重大责任事故/不报谎报
	第 3 章破坏社会主义市场经济秩序罪	（37）生产销售伪劣产品罪（**药品**★、食品犯罪，**法条竞合择重**）；（38）走私犯罪；（39）非国家工作人员受贿罪★，为亲友非法牟利罪★；（40）假币犯罪，**洗钱罪**★；（41）**集资诈骗罪**（非法吸收公众存款罪），**贷款诈骗罪**（骗取贷款罪）★；**信用卡诈骗罪**；票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪；保险诈骗罪；（42）逃税罪，骗取出口退税罪，虚开增值税专用发票罪；（43）假冒注册商标罪，**侵犯著作权罪**★，**侵犯商业秘密罪（商业间谍）**★；（44）合同诈骗罪，**非法经营罪**，强迫交易罪
	第 4 章侵犯公民人身权利、民主权利罪	（45）故意杀人罪，故意伤害罪，过失致人死亡罪；（46）**人体器官类犯罪**；（47）强奸罪，猥亵犯罪，**负有照护职责人员性侵罪**★；（48）**非法拘禁罪**；（49）**绑架罪**；（50）拐卖妇女、儿童罪；（51）诬告陷害罪；诽谤罪，侮辱罪；（52）**刑讯逼供罪，暴力取证罪，虐待被监管人罪**；（53）**遗弃罪，虐待罪，虐待被监护、看护人罪**；重婚罪，破坏军婚罪；（54）强迫劳动罪，雇用童工从事危重劳动罪；侵犯公民个人信息罪
	第 5 章侵犯财产罪	（55）**他人占有的财物**，非法占有目的；（56）**抢劫罪**（普通抢劫，转化型抢劫，携凶抢夺，加重犯），抢夺罪；（57）**敲诈勒索罪**；（58）**盗窃罪**（五种形式）；（59）**诈骗罪**（与盗窃区分）；（60）**侵占罪**（与盗窃区分）；（61）故意毁坏财物罪，拒不支付劳动报酬罪
	第 6 章妨害社会管理秩序罪	（62）妨害公务罪/**袭警**★，招摇撞骗罪，伪造证章犯罪，冒名顶替罪★；（63）寻衅滋事罪，聚众斗殴罪，**催收非法债务罪**★；网络犯罪、虚假信息犯罪，**高空抛物罪**★；**考试舞弊**；黑社会犯罪；赌博犯罪★；（64）**妨害司法犯罪**；（65）组织、运送他人偷越国（边）境犯罪；（66）文物犯罪；（67）**非法行医罪**，医疗事故罪；妨害传染病防治罪★；（68）**林木、动物**；污染环境罪★；（69）**毒品犯罪**；（70）组织卖淫罪，强迫卖淫罪，传播性病罪；（71）淫秽物品犯罪
	第 8 章贪污贿赂罪	（72）**国家工作人员**；（73）**贪污罪**；（74）**挪用公款罪**；（75）**受贿罪**，**利用影响力受贿罪**，行贿罪★；（76）私分国有资产罪，巨额财产来源不明罪
	第 9 章渎职罪	（77）渎职罪中**法条竞合**；与对象人共谋，罪数；（78）滥用职权罪，玩忽职守罪；（79）**徇私枉法罪**，司法工作人员犯罪，徇私舞弊不移交刑事案件罪；（80）其他渎职罪名

方鹏刑法讲义

目　录

Contents

上编　刑法总论

刑法总论的知识体系 …… 1

第一章　刑法概说 …… 2

第一节　刑法的概念和规范形式 …… 2

第二节　刑法的基本思维和案件推理方法 …… 4

★第三节　刑法解释 …… 7

★第四节　刑法的基本原则 …… 14

第五节　刑法的适用范围 …… 17

第二章　犯罪构成理论（客观不法—主观责任） …… 27

★第一节　犯罪构成理论和犯罪推理逻辑 …… 27

第二节　构成要件要素及其分类 …… 34

第三章　法益（犯罪客体） …… 37

第四章　客观不法要件（犯罪的客观要件） …… 39

★第一节　危害行为 …… 39

第二节　行为对象 …… 52

第三节　危害结果 …… 52

★第四节　因果关系 …… 54

第五节　其他客观不法要素 …… 66

第五章　主观责任要件（犯罪的主观要件） …… 67

第一节　刑事责任年龄 …… 67

第二节　刑事责任能力（精神状况） …… 74

★第三节　故意、过失（罪过形式） …… 78

第四节　犯罪目的、犯罪动机 …… 93

★第五节　事实认识错误 …… 94

方鹏刑法讲义

★第六章　犯罪阻却事由（违法阻却事由+责任阻却事由） …… 107
第一节　违法阻却事由（正当化事由） …… 107
第二节　责任阻却事由 …… 125
第七章　犯罪形态（既遂、中止、未遂、预备） …… 129
第一节　犯罪既遂（既遂结果+实行行为+因果关系） …… 130
★第二节　犯罪中止（自动放弃+有效防止既遂结果发生） …… 133
第三节　犯罪未遂（被迫停顿+着手实行后） …… 139
第四节　犯罪预备（被迫停顿+着手实行前） …… 140
第五节　犯罪未遂与不可罚的不能犯 …… 141
★第八章　共同犯罪 …… 144
第一节　共同犯罪的核心内容：不法行为共同说 …… 144
第二节　共同犯罪的成立条件：共同行为+共同故意 …… 153
第三节　共同犯罪人的分工分类法：正犯与共犯【帮助犯、教唆犯】（定罪之用） …… 159
第四节　共同犯罪人的作用分类法：主犯与从犯（量刑之用） …… 167
第五节　共同犯罪与身份 …… 170
第六节　共同犯罪与不作为 …… 172
第七节　共同犯罪中的认识错误 …… 173
第八节　共同犯罪与犯罪形态（既遂、中止、未遂、预备） …… 175
第九章　单位犯罪 …… 183
★第十章　罪数规则（总论理论+分则规定） …… 187
第一节　行为单数的特殊情形（继续犯、集合犯） …… 189
第二节　刑法分则规定罪数规则（法条竞合、结果加重犯、结合犯） …… 191
第三节　刑法总论中的罪数规则 …… 193
第四节　刑法分则及解释规定的常考罪数规则（结合犯；加重犯等） …… 200
第十一章　刑罚体系 …… 206
第一节　主刑 …… 206
第二节　附加刑 …… 214
第十二章　刑罚的裁量 …… 220
第一节　量刑概述 …… 220
★第二节　量刑情节（累犯、自首、坦白、立功） …… 222
第三节　数罪并罚（数刑并罚） …… 232
★第十三章　刑罚执行（缓刑、假释、减刑） …… 238
第一节　缓刑（量刑时决定的附条件不执行的刑罚执行方式） …… 239
第二节　减刑（刑罚执行期间缩短原刑期） …… 240

方鹏刑法讲义

第三节　假释（刑罚执行期间附条件提前释放）　…… 243
第十四章　刑罚消灭 …… 247
★第一节　追诉时效 …… 247
第二节　赦免 …… 250

下编　刑法分论

第一章　危害国家安全罪 …… 258
第二章　危害公共安全罪 …… 263
第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪 …… 293
★第一节　生产、销售伪劣商品罪 …… 293
第二节　走私罪 …… 300
第三节　妨害对公司、企业的管理秩序罪 …… 305
第四节　破坏金融管理秩序罪 …… 309
★第五节　金融诈骗罪 …… 315
★第六节　危害税收征管罪 …… 330
★第七节　侵犯知识产权罪 …… 335
第八节　扰乱市场秩序罪 …… 339
★第四章　侵犯公民人身权利、民主权利罪 …… 345
第一节　侵害生命健康犯罪 …… 345
第二节　性犯罪 …… 355
第三节　侵犯人身自由的犯罪 …… 362
第四节　拐卖、收买妇女、儿童类犯罪 …… 373
第五节　侵犯人格尊严犯罪 …… 377
第六节　婚姻家庭犯罪 …… 383
第七节　本节其他犯罪 …… 386
★第五章　侵犯财产罪 …… 392
第六章　妨害社会管理秩序罪 …… 434
★第一节　扰乱公共秩序罪 …… 434
★第二节　妨害司法罪 …… 452
第三节　妨害国（边）境管理罪　…… 467
第四节　妨害文物管理罪 …… 469
第五节　危害公共卫生罪 …… 472
第六节　破坏环境资源保护罪 …… 475
第七节　走私、贩卖、运输、制造毒品罪 …… 479

方鹏刑法讲义

第八节　组织、强迫、引诱、容留、介绍卖淫罪 …… 484
第九节　制作、贩卖、传播淫秽物品罪 …… 488
第七章　危害国防利益罪 …… 491
★第八章　贪污贿赂罪 …… 492
第一节　国家工作人员；利用职务上的便利 …… 492
第二节　侵害公共财产权的职务犯罪 …… 497
第三节　贿赂犯罪 …… 510
第四节　兜底型罪名 …… 525
★第九章　渎职罪 …… 527
第十章　军人违反职责罪 …… 542

方鹏刑法讲义

★第八章　贪污贿赂罪

本章贪污贿赂罪，主要包括：贪污罪、挪用公款罪；私分类犯罪（私分国有资产罪、私分罚没财物罪）；贿赂犯罪（受贿罪、行贿罪；利用影响力受贿罪、对有影响力的人行贿罪等）；兜底型罪名（巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪）。侵害的法益是职务行为的廉洁性，贪污罪、挪用公款罪等还侵害了公共财产权。

从主体身份上区分，本章罪名的主体可分为四类：（1）一是国家工作人员，是贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、巨额财产来源不明罪、隐瞒境外存款罪的主体（贪污罪的主体另有受民事委托人员）。（2）二是国有单位，是私分国有资产罪、私分罚没财物罪、单位受贿罪的主体。（3）三是国家工作人员的“身边人”，如近亲属、关系密切人、离职国家工作人员及其近亲属、关系密切人，是利用影响力受贿罪的主体。（4）四是一般主体（自然人），是对合犯罪、关联犯罪（如行贿罪、对有影响力的人行贿罪、介绍贿赂罪、对单位行贿罪等罪名）的主体。单位行贿罪的主体是单位，对单位行贿罪的主体也包括单位。

第八章　贪污贿赂罪（14）		
第 382 条	贪污罪	国家工作人员；受民事委托人员
第 384 条	挪用公款罪	国家工作人员
第 395 条第 1 款	巨额财产来源不明罪	国家工作人员
第 395 条第 2 款	隐瞒境外存款罪	国家工作人员
第 396 条第 1 款	私分国有资产罪	国家机关、国有单位
第 396 条第 2 款	私分罚没财物罪	司法机关、行政执法机关
第 385 条	受贿罪	国家工作人员
第 389 条	行贿罪	自然人→国家工作人员
第 388 条之一	利用影响力受贿罪	国工、离职国工近亲属、关系密切人，离职国工
第 390 条之一	对有影响力的人行贿罪	自然人→国工、离职国工近亲属、关系密切人，离职国工
第 392 条	介绍贿赂罪	自然人→介绍自然人、单位→国工自然人
第 387 条	单位受贿罪	国家机关、国有单位
第 391 条	对单位行贿罪	自然人、单位→国家机关、国有单位
第 393 条	单位行贿罪	单位→国工自然人

第一节　国家工作人员；利用职务上的便利

由于本章的很多罪名（贪污罪、挪用公款罪、受贿罪）有两个共同要素，即主体身份是

方鹏刑法讲义

国家工作人员，且要求利用职务上的便利。因此以下先讲解这两个共同要素。

★（一）国家工作人员：四类单位+从事公务

【《中国审判案例要览（2002年刑事审判案例卷）》：白朝栋挪用公款、孙月娟职务侵占案〔1〕】白朝栋于1999年4月至2000年5月，在担任北京邮电大学培训中心学七楼管理员期间，受学校委托负责收取学员住宿费、培训费，除其自己收取以外，还委托服务员孙月娟等人代为收取。服务员将收取的现金和开出的发票交回后，白朝栋向服务员出具收款白条，然后将现金和发票交财务处报账。至2000年5月，经对开出的发票和收取的现金进行核对，共短款165 760元，其中，白朝栋私自截留住宿费、培训费共计人民币143 785元，拒不上交财务部门。1998年11月至1999年11月间，被告人孙月娟受白朝栋委托，在代收学员培训费的过程中，利用职务之便，私自截留公款人民币21 975元，用于个人挥霍，并不辞而别，离开单位，将上述公款据为己有。

【问题】白朝栋、孙月娟二人是否属于国家工作人员，二人构成何罪？

【相关法条】

第93条【国家工作人员】本法所称国家工作人员，是指国家机关中从事公务的人员。

国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员，以及其他依照法律从事公务的人员，以国家工作人员论。

【考点精析】

<table>
<tr><td rowspan="7">国家工作人员</td><td rowspan="3">国家机关中从事公务的人员</td><td>（1）宪法：国家权力机关、行政机关、司法机关、监察机关、军事机关中从事公务的人员</td><td rowspan="7">依照法律从事公务</td></tr>
<tr><td>（2）党口、参公等：参照公务员条例管理的党、政、机关人员</td></tr>
<tr><td>（3）立法解释规定的3种人（比照行政法）：
①依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员；
②在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员；
③虽未列入国家机关人员编制，但在国家机关中行使职权的人员</td></tr>
<tr><td>国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员</td><td>国有公司、企业指国有全资公司、企业；人民团体（如乡级以上工会、共青团、妇联）区别于社会团体</td></tr>
<tr><td>国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员</td><td>行政委派</td></tr>
<tr><td rowspan="2">其他依照法律从事公务的人员</td><td>立法解释：村民委员会等基层组织人员协助政府从事公务（7种公务）</td></tr>
<tr><td>人民陪审员、人大代表、政协委员等</td></tr>
</table>

〔1〕国家法官学院、中国人民大学法学院编：《中国审判案例要览（2002年刑事审判案例卷）》，中国人民大学出版社2003年版。

方鹏刑法讲义

续表

★1. **国家工作人员［公务说］**有四类：国家机关、国有单位、行政委派、其他公务人员（如村干部协公）+**从事公务**；只要从事公务，即使没有编制，也是国家工作人员。 2. 行为人有多种身份，以实际利用的身份定罪。没有利用身份，定普通犯罪。 3. 特别注意几种人：村干部、公立高校、公立医院、临时工。

根据《刑法》第 93 条的规定，国家工作人员包括以下四类人员：

1. **国家机关中从事公务的人员**。此类人员不仅是本章贪污贿赂罪的主体，而且是刑法分则第九章渎职罪的主体。

（1）宪法：国家机关中从事公务的人员，指各级国家权力机关（各级人大及常委会）、行政机关（各级政府及职能部门）、司法机关（各级法院、各级检察院）、监察机关、军事机关（各级军区或战区）中从事公务的人员。

（2）党口、参公等：参照国家公务员条例进行管理的人员，应当以国家机关工作人员论。例如，根据中央和国务院有关规定，参照国家公务员条例管理的各级党委、政协机关中从事公务的人员，应视为国家机关工作人员。

（3）根据 2002 年 12 月 28 日全国人大常委会《关于〈中华人民共和国刑法〉第九章渎职罪主体适用问题的解释》，以下人员（三种人）也视为国家机关工作人员（比照行政法）：

①在依照法律、法规规定行使国家行政管理职权的组织中从事公务的人员。例如中国银行保险监督管理委员会（简称银保监会）、证监会中从事监督管理工作的人员，系国家机关工作人员。

②在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员。例如在行政机关委托某公司从事某项行政管理工作（委托行政），在该受委托行政的公司中从事行政管理工作的人员，系国家机关工作人员。

③虽未列入国家机关人员编制，但在国家机关从事公务的人员。例如，合同制民警在从事警察工作时，系国家机关工作人员。

2. **国有全资单位：国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员。**

（1）国有公司，是指依照公司法成立，财产全部属于国家所有的公司。国有资本控股及参股的股份有限公司，不属于国有公司。

（2）国有企业，是指财产全部属于国家所有，从事生产、经营活动的营利性的非公司化经济组织。

（3）国有事业单位，是指受国家机关领导，财产属于国家所有的非生产、经营性单位，包括国有医院、科研机构、体育、广播电视、新闻出版等单位。

（4）人民团体，是指由国家组织成立的、财产属于国家所有的各种群众性组织，包括乡级以上工会、共青团、妇联等组织。

3. **国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员。**

这里的委派是指“行政委派”，即受有关国有单位委任而派往非国有单位从事公务，关键在于派出单位是国家机关、国有单位。被委派的人员，在被委派以前可以是国家工作人员，也可以是非国家工作人员。不论被委派以前具有何种身份，只要被有关国有单位委派到非国有单位从事公务，就应视为国家工作人员。

根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》以及《全国法院审理经济犯罪案件工作座谈会纪要》，这里的“委派”包

微博“刑法学人方鹏”：学好真刑法，仗剑走天涯

方鹏刑法讲义

括经由国家机关、国有单位、监管组织提名、推荐、任命、批准、决定。

（1）经国家机关、国有公司、企业、事业单位提名、推荐、任命、批准等，在国有控股、参股公司及其分支机构中从事公务的人员，应当认定为国家工作人员。具体的任命机构和程序，不影响国家工作人员的认定。

（2）经国家出资企业中负有管理、监督国有资产职责的组织批准或者研究决定，代表其在国有控股、参股公司及其分支机构中从事组织、领导、监督、经营、管理工作的人员，应当认定为国家工作人员。

（3）国家出资企业中的国家工作人员，在国家出资企业中持有个人股份或者同时接受非国有股东委托的，不影响其国家工作人员身份的认定。

4. **其他依照法律从事公务的人员。**

其他依照法律从事公务的人员的特征是，在一定条件下代表国家行使国家管理职能。

（1）**协助政府从事管理工作的村民委员会、居民委员会等基层组织人员**。根据 2009 年 8 月 27 日全国人大常委会关于《刑法》第 93 条第 2 款的立法解释：村民委员会等村基层组织人员协助人民政府从事下列行政管理工作，属于《刑法》第 93 条第 2 款规定的“其他依照法律从事公务的人员”：①救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的管理；②社会捐助公益事业款物的管理；③国有土地的经营和管理；④土地征收、征用补偿费用的管理；⑤代征、代缴税款；⑥有关计划生育、户籍、征兵工作；⑦协助人民政府从事的其他行政管理工作。

比照上述解释的精神，协助政府从事管理工作的居民委员会等城镇基层组织人员，也属国家工作人员。例如，协助街道办事处从事行政管理工作的居民委员会工作人员，亦属国家工作人员。

由此可知：村民委员会（村民小组）、居民委员会等，在宪法层面上属于农村、城镇的群众自治组织或集体组织，而不属于国家机关、国有单位。①在管理村集体、居民小区事务时（一般情形），基层组织人员（如村主任、村支书、小组长；居委会主任、书记；会计、成员等）不是国家工作人员，系一般单位人员。②在协助政府从事公务时（相当于该国家机关临时聘请人员），才是国家工作人员（或国家机关工作人员）。

（2）其他依照法律从事公务的人员，还包括：①依法履行职责的各级人民代表大会代表；②依法履行职责的各级人民政协委员；③依法履行审判职责的人民陪审员；④其他由法律授权从事公务的人员。

5. 国家工作人员的本质特征：**依照法律从事公务**。

我国刑法对国家工作人员的本质界定，采用**“公务说”**的标准，亦即凡是依照法律从事公务的人员，均为国家工作人员，而无论其是否具有国家工作人员的资格身份（干部身份）。例如，国有事业单位里的工人被事业单位授权管理事业单位资金的，认为是国家工作人员。国有企业中临时聘用的出纳，虽无正式编制，但因其从事管理国有资产的工作，也认为是国家工作人员。还有，通过伪造国家机关公文、证件担任了国家工作人员的，只要其从事公务，也是国家工作人员。

（1）“从事公务”，是指代表国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体等履行组织、领导、监督、管理等职责。

公务主要表现为与职权相联系的公共事务以及监督、管理国有财产的职务活动。如国家机关工作人员依法履行职责，国有公司的董事、经理、监事、会计、出纳人员等管理、监督国有财产等活动，均属于从事公务。公务一般关系到多数人或不特定人的利益，公务是由国家机关或者其他法定的公共机构或者公共团体（如国有企业、事业单位、人民团体等）组织或者安排的事务，系职权活动。公民自发从事的公益性活动，不属于公务。公务一般表现为裁量性、

判断性、决定性的事务，与一般劳务有明显区别但与劳务并不绝对对立。当然，那些不具备职权内容的劳务活动、技术服务工作，如售货员、售票员等所从事的工作，一般不认为是公务。

（2）“依照法律”，实质上是依法的含义，指行为人所从事的公务行为等具有法律上的根据，其从事的事务是基于其任用、地位、职务，要求主体必须代表国家从事活动或者以国家的名义从事活动。至于行为人取得国家工作人员这一特殊身份的途径是否正当，则不影响国家工作人员的认定。

（二）利用职务上的便利

利用职务上的便利，通常是指利用职务权力与地位所形成的主管、管理、经营、经手公务或公共财物的便利条件；而不是仅因工作关系熟悉作案环境，或者利用劳务。

（1）主管，是指国家工作人员不具体负责经手、管理公务或公共财物，但依其职权范围具有调拨、使用或者以其他方式支配公共财物的权力。

（2）管理，是指具有监守公务或保管公共财物的职权。

（3）经营，是指从事经营性的公务，将公共财物投放市场进行营利活动，或者利用公共财物从事非营利活动。经营者在经营期间通常同时行使管理职权，对公共财物具有处置权。

（4）经手，是指具有领取、支出等经办公共财物的流转事项的权限，经手人虽然不负责公共财物的管理和处置，但具有基于职务产生的对公共财物的临时控制权。

利用与职务无关仅因工作关系熟悉作案环境，或者易于接近作案目标，或者凭工作人员身份容易进入某些单位等方便条件，不属于利用职务上的便利，不构成贪污贿赂罪，而应构成普通犯罪，例如盗窃罪、诈骗罪、侵占罪、敲诈勒索罪等。行为人具有多种身份时，以实际利用的身份定罪。

贪污罪、挪用公款罪中的利用职务上的便利，是指主管、管理、经营、经手公共财物的便利条件，即基于公务（职权）对公共财物有占有、控制、支配关系。而受贿罪中的利用职务上的便利，含义更为宽泛。除包括前述内容以外，还有“利用职位上便利条件”的含义，亦即，只要收受的钱物与国家工作人员的职权、职位存在关联，都可认为是受贿罪。

【经典考题】

2016/2/62. 关于贿赂犯罪的认定，下列哪些选项是正确的？〔1〕

A. 甲是公立高校普通任课教师，在学校委派其招生时，利用职务便利收受考生家长10万元。甲成立受贿罪

B. 乙是国有医院副院长，收受医药代表10万元，承诺为病人开处方时多开相关药品。乙成立非国家工作人员受贿罪

C. 丙是村委会主任，在村集体企业招投标过程中，利用职务收受他人财物10万元，为其谋利。丙成立非国家工作人员受贿罪

D. 丁为国有公司临时工，与本公司办理采购业务的副总经理相勾结，收受10万元回扣归二人所有。丁构成受贿罪

【拓展习题】

以下关于贪污贿赂犯罪，说法正确的有？〔2〕

A. 村民委员会主任甲在任职期间，利用职务上的便利，在村自来水改道工程、道路维修等工程中，侵吞有关款项8万元。甲构成贪污罪

B. 乙在某个受国家机关委托的代表国家机关行使职权的组织中从事公务，系企业编制人员，在其履行职务期间将收取的办事费用据为己有挥霍。乙构成贪污罪

---

〔1〕 ABCD 〔2〕 BD

方鹏刑法讲义

C. 丙与某国有公司签订承包租赁合同承包该公司供销部门，丙利用经营便利，将该供销部门的机器设备盗卖后将款项挪用炒股。丙构成挪用公款罪

D. 某国有公司A公司委派其工作人员丁到A公司参股的B公司担任总经理，丁利用B公司总经理职务便利，让有生意往来的C公司免费为其装修私房（装修价值100万元）。丁构成受贿罪

第二节　侵害公共财产权的职务犯罪

★一、贪污罪：两类人员监守自盗

【指导案例11号：杨延虎等贪污案】杨延虎在任浙江省义乌市委常委、兼任该市国际商贸城建设领导小组副组长兼指挥部总指挥期间，得知某村将列入拆迁和旧村改造范围后，决定在该村购买旧房，在拆迁安置时骗取非法利益。遂与王月芳（杨延虎的妻妹）、郑新潮（王月芳之夫）共谋后，由王、郑二人出面，通过共和村王某某，以王月芳的名义在该村购买赵某某的3间旧房（房产证登记面积61.87平方米），编造了由王月芳等人签名的申请报告，谎称“占地90.2平方米”，要求义乌市国土资源局更正。随后，杨延虎利用职务便利，指使其下属的国际商贸城建设指挥部工作人员以该部名义对该申请报告盖章确认，并使该申请报告得到义乌市国土资源局和义乌市政府认可，从而让王月芳、王某祥多获得补偿建设用地90平方米，实际非法所得229 392万元。

【问题】杨延虎与王月芳等人勾结，指使下属对申请报告确认，多骗取补偿土地，构成何罪？

【相关法条】

第382条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。

受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。

与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。

第394条【贪污罪的提示条款】国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，依照本法第三百八十二条、第三百八十三条（贪污罪）的规定定罪处罚。

【考点精析】

贪污罪，是指国家工作人员，以及受国家机关、国有单位委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。本罪的法益是职务行为的廉洁性和公共财物的所有权。

（一）构成要件要点

1. 主体身份（身份犯）包括两类：国家工作人员，受民事委托人员（非国家工作人员）。

（1）国家工作人员。指《刑法》第93条规定的四类依照法律从事公务的人员。

国有保险公司的工作人员和国有保险公司委派到非国有保险公司从事公务的人员（《刑法》第183条第2款），国有公司、企业或者其他国有单位委派到非国有公司、企业以及其他单位从事公务的人员（《刑法》第271条第2款），属于前述《刑法》第93条国家工作人员第三类人员。其利用职务上的便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归

自己所有的，或者将本单位财物非法占为己有的，当然以贪污罪论处。

通过伪造国家机关公文、证件担任国家工作人员，之后利用担任该职务的便利非法占有公共财物的，以伪造国家机关公文、证件罪，贪污罪数罪并罚。

（2）受民事委托人员：受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员（以下简称“受民事委托人员”）。“受委托管理、经营国有财产”的人员是指因承包、租赁、临时聘用等管理、经营国有财产的人员。

①受民事委托：与国有单位签订承包、租赁、临时聘用合同（民事合同）。这里的“受委托”（民事委托）与前述国家工作人员第三类人员“受委派”（行政委派）不同，受委托是民事委托，受委托人员不是国家工作人员（是贪污罪主体，不是受贿罪、挪用公款罪主体）；受委派是行政委派，受委派人员是国家工作人员（系贪污罪、受贿罪、挪用公款罪主体）。

②被委托人原本不是管理、经营国有财产的人员。

③委托单位必须是国有单位，即国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体。

④此类人员属于非国家工作人员，只能成为本罪即贪污罪的主体，不能成为受贿罪、挪用公款罪的主体，其受贿构成非国家工作人员受贿罪，挪用单位资金构成挪用资金罪。

【楼长贪污案】张某某，原系上海市宝山区张庙街道新江内燃机厂公寓（原厂停产，改建为公寓）负责人。2022年4月，被告人张某某出于非法占有目的，单独或伙同他人，将上海市宝山区张庙街道委托发放的蔬菜等防疫生活保障物资予以侵吞并对外出售。相关物资系政府出资采购或由兄弟省市政府捐赠，价值共计1.3万余元。

【问题】张某某是否构成贪污罪？

2. 利用职务上的便利。

指利用职务上主管、管理、经营、经手公共财物的权力及方便条件，而不是单纯地利用熟悉作案环境。

3. 以侵吞、窃取、骗取或者其他手段非法占有公共财物。

（1）侵吞、窃取、骗取。

①侵吞就是侵占的意思，将自己因为职务而占有、管理的公共财物据为己有。例如，国有单位出纳将收取的货款据为己有。

②窃取即是盗窃的意思，即将行为人与他人共同占有的公共财物，窃取据为己有。例如，国有银行共管金库的一人，趁其他共管人不注意拿走金库里的现金。

③骗取就是诈骗的意思，即假借职务上的合法形式，采用欺骗手段，使具有处分权的受骗人产生认识错误，而取得公共财物。例如，国有保险公司工作人员，利用经手保险理赔的职务便利，编造未曾发生的保险事故，骗取保险金据为己有。

（2）其他手段。

只要利用职务上的便利非法占有公共财物，都可构成贪污，并不限定手段、形式。例如，国有公司的保管人员，不侵吞、窃取、骗取，而是直接破坏自己保管仓库的锁具，将保管物品据为己有，也认定是贪污。

（3）国家工作人员在国内公务活动或者对外交往中接受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大的，构成本罪（《刑法》第394条）。

4. 对象是公共财物，包括：

（1）国有财物。

（2）在国家机关、国有公司、企业、集体企业和人民团体管理、使用或者运输中的私人财产。

（3）国家工作人员基于职务而主管、管理、经营、经手的非国有财物。例如，委派到非国

方鹏刑法讲义

有公司中从事公务的人员，主管、管理、经营、经手的该单位财物。

5. 责任：故意，非法占有目的。

6. 贪污罪的既遂标准：实际控制财物。

贪污罪是一种以非法占有为目的的财产性职务犯罪，与盗窃、诈骗、抢夺等侵犯财产罪一样，应当以行为人是否实际控制财物作为区分贪污罪既遂与未遂的标准。对于行为人利用职务上的便利，实施了虚假平账等贪污行为，但公共财物尚未实际转移，或者尚未被行为人控制就被查获的，应当认定为贪污未遂。行为人控制（事实控制、法律控制）公共财物后，是否将财物据为己有，不影响贪污既遂的认定。例如，将公款划入自己本人控制的账户后，还未取出即被抓获，也构成既遂。

【经典考题】

2008 川延/2/65. 下列哪些行为应当以贪污罪论处？〔1〕

A. 国家工作人员甲在国内公务活动中收受礼物，依照国家规定应当交公而不交公，数额较大

B. 乙受国家机关的委托经营某小型国有企业，利用职务上的便利，将该国有企业的资产转移到个人名下

C. 国家工作人员丙利用职务上的便利，挪用公款数额巨大不能退还

D. 国家工作人员丁利用职务之便，将依法扣押的陈某私人所有的汽车据为己有

（二）贪污罪与共同犯罪

贪污罪是身份犯，无身份者与有身份者共同犯罪（内外勾结），适用总论中共同犯罪与身份的规则。

1. 一般公民与具备贪污罪主体身份的人员（国家工作人员，受民事委托人员）相勾结，**主要利用其职务便利**，伙同贪污的，以贪污罪的共犯论处。

2. 无身份者与有身份者相勾结，没有利用有身份者的职务便利，而是主要利用其他手段（如诈骗、盗窃），则不能构成贪污罪，应以诈骗罪、盗窃罪等论处。

3. 公司、企业或者其他单位中，不具有国家工作人员身份的人与国家工作人员勾结，分别利用各自的职务便利，共同将本单位财物非法占为己有的，按照主犯的犯罪性质定罪（《最高人民法院关于审理贪污、职务侵占案件如何认定共同犯罪几个问题的解释》第 3 条）。这里的“主犯”以职务作用大者为主犯；都主管该项事务，职位高者为主犯；只有一人主要主管该项事务，实际主管者为主犯。不能区分作用大小，以贪污罪认定。

【经典考题】

2022/客/1/27 仿. 刘某是甲建筑公司（国有企业）的普通员工，受公司委派去监督乙公司（乙公司的负责人为李某）承接的甲公司的某项工程施工，第三方监理为方某。刘某、李某、方某三人合谋，由乙公司虚报土方数（虚增工程款数额 200 万元），乙公司负责人李某签字，第三方监理方某确认，刘某将土方数报给了甲公司。为此，甲公司向乙公司多支付了 200 万元。乙公司收到该款项后，刘某、李某、方某每人分得 20 万元，剩下 140 万元用于乙公司的日常经营。关于本案，下列说法不正确的有？〔2〕

A. 刘某虽然不是国家工作人员，但也应认定为贪污罪，犯罪数额为 60 万元

B. 刘某应当认定为职务侵占罪，犯罪数额为 200 万元

C. 李某虽然不是国家工作人员，但也应认定为贪污罪，犯罪数额为 60 万元

D. 方某虽然不是国家工作人员，但也应该认定为职务侵占罪，数额为 20 万元

〔1〕 ABD 〔2〕 ABCD

（三）此罪彼罪

1. **贪污罪与侵占罪、盗窃罪、诈骗罪的关系**：关键是看是否利用了职务上的便利。

例如，国有公司的会计（只管账不管钱），窃取了出纳的保险柜钥匙，盗走保险柜里的单位公款，没有利用职务上的便利，应当认定为盗窃罪。而国有公司的出纳（管理保险柜），将自己掌管的保险柜里的现金据为己有，然后伪造盗窃现场，谎称被盗，获取现金利用了职务上的便利，应当认定为贪污罪。

主体身份	利用职务与否	罪名	关系
一般主体	单纯利用熟悉作案环境（以及劳务便利）	**盗窃罪、诈骗罪、侵占罪**	部分法
单位人员	利用主管、管理、经营、经手单位财物的一般职务便利	**职务侵占罪**	一般法
国家工作人员 受委托管理、经营国有财产的人员	利用主管、管理、经营、经手公共财物的职权及公务便利	**贪污罪**	特别法

【经典考题】

2002/2/9. 李某系A市建设银行某储蓄所记账员。2002年3月20日下午下班后，李某发现本所出纳员陈某将2万元营业款遗忘在办公桌抽屉内（未锁）。当日下班后，李某趁所内无人之机，返回所内将该2万元取出，用报纸包好后藏到自己办公桌下面的垃圾袋内，并用纸箱遮住垃圾袋。次日上午案发，赃款被他人找出。对此，下列哪一说法是正确的？〔1〕

A. 李某的行为属于贪污既遂　　B. 李某的行为属于贪污未遂

C. 李某的行为属于盗窃既遂　　D. 李某的行为属于盗窃未遂

2. **贪污罪与职务侵占罪的区分**：主体身份不同。

一般可从主体身份上进行区分：国家工作人员非法占有本单位财产构成贪污罪；非国家工作人员（即一般单位人员）非法占有本单位财产构成职务侵占罪。当行为人同时具有国家工作人员、非国家工作人员双重身份时，看其占有本单位财物，实际利用的何种身份。例如，某民营工厂的厂长被选为副镇长，但利用厂长身份将民营工厂的财物据为己有，构成职务侵占罪；若利用副镇长身份将该民营工厂上缴给镇政府的财物据为己有，构成贪污罪。

事实上，贪污罪应是职务侵占罪的特别法条，因为国家工作人员是更为特别的单位人员。

3. **贪污罪**（内外勾结贪污公款）**与受贿罪的区分**：对方给予财物的应然权属归谁。

在贪污案经常出现国家工作人员与无身份者内外勾结伙同贪污公款的情形，这种情形在表面上，国家工作人员也是从无身份者手中拿钱（分赃）；而受贿罪中，国家工作人员也是从无身份者手中拿钱（收贿）。两者具有相似性，往往难以区分。

贪污罪（内外勾结贪污公款）与受贿罪（给予财物换取职务行为）的关键区分在于：国家工作人员获取的钱款的应然权属归谁。（1）应然权属系公共财物或国有财物的，构成贪污罪；（2）系请托人的财物的，构成受贿罪。

对方给予的财物的应然权属		
应归公有或国有	伙同贪污，分赃	**贪污罪**：对象是公共或国有财物
是给予个人的（用于换取职务行为）	收取职务行为对价	**受贿罪**：对象是请托人给予的职务行为对价

〔1〕 C

方鹏刑法讲义

【经典考题】

2014/2/21. 交警甲和无业人员乙勾结，让乙告知超载司机“只交罚款一半的钱，即可优先通行”；司机交钱后，乙将交钱司机的车号报给甲，由在高速路口执勤的甲放行。二人利用此法共得32万元，乙留下10万元，余款归甲。关于本案的分析，下列哪一选项是错误的？〔1〕

A. 甲、乙构成受贿罪共犯　　B. 甲、乙构成贪污罪共犯

C. 甲、乙构成滥用职权罪共犯　　D. 乙的受贿数额是32万元

（四）贪污罪（受贿罪）的处罚

第383条【对犯贪污罪、受贿罪的处罚规定】对犯贪污罪的，根据情节轻重，分别依照下列规定处罚：

（一）贪污**数额较大**或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

（二）贪污**数额巨大**或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

（三）贪污**数额特别巨大**或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产；数额特别巨大，并使国家和人民利益遭受特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

对多次贪污未经处理的，按照累计贪污数额处罚。

犯第一款罪，在提起公诉前如实供述自己罪行、真诚悔罪、积极退赃，避免、减少损害结果的发生，有第一项规定情形的，可以从轻、减轻或者免除处罚；有第二项、第三项规定情形的，可以从轻处罚。

犯第一款罪，有第三项规定情形被判处死刑缓期执行的，人民法院根据犯罪情节等情况可以同时决定在其死刑缓期执行二年期满依法减为无期徒刑后，**终身监禁**，不得减刑、假释。

“两高”司法解释贪污受贿定罪量刑标准

法条	一般标准	有其他特定较重情节的	法定刑
数额较大	3万元以上	1万元以上	3年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金
数额巨大	20万元以上	达到起点一半（10万元），同时具有特定情节的	3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产
数额特别巨大	300万元以上	达到起点一半（150万元），同时具有特定情节的	10年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处罚金或者没收财产
死缓	符合死刑立即执行条件但同时具有法定从宽等处罚情节，不是必须立即执行的		
死缓终身监禁适用	判处死刑立即执行过重，判处一般死缓又偏轻，可以决定终身监禁。在一、二审作出死缓裁判时一并作出，而非等到死缓执行届满再视情况而定。终身监禁决定一经作出应无条件执行，不得减刑、假释		
死刑立即执行	犯罪数额特别巨大，犯罪情节特别严重，社会影响特别恶劣，造成损失特别重大		

〔1〕 B

常见罪名数额起点标准（既遂）

基准		二倍（2016年《两高贪污贿赂解释》）		一倍（2022年《最高检、公安部追诉标准（二）》）
贪污罪	3万	职务侵占罪	6万	3万
受贿罪、利用影响力受贿罪		非国家工作人员受贿罪		
行贿罪、对有影响力的人行贿罪		对非国家工作人员行贿罪		
挪用公款罪	3万；5万；5万	挪用资金罪、挪用特定款物罪	6万；10万；10万	3万；5万；5万
盗窃罪	1千~3千			
抢夺罪	1千~3千			
诈骗罪	3千~1万			
敲诈勒索罪	2千~5千			
故意毁坏财物罪	5千			

【考点归纳】

1. **两类人员**（国家工作人员，受民事委托人员），利用职务盗、骗、侵，应当交公不交公，构成贪污罪。

★2. 利用熟悉环境（以及劳务便利），是盗窃、诈骗、侵占；利用一般职务便利，是职务侵占；利用公务便利，是贪污。

★3. **贪污与受贿区分**：对方给予的财物应归公有，是贪污；应属请托人，给予个人换取职务行为的对价，是受贿。

★4. 共犯与身份：不同身份人相互勾结，以主犯身份定；不能区分作用大小，定贪污罪。

5. 终身监禁：犯贪污罪、受贿罪，判处死缓，审判时决定，减为无期后不得减刑、假释。修九前实施，从旧兼从轻。

【拓展习题】

下列情形中应当以贪污罪论处的有？〔1〕

A. A市市长甲，在出国考察时接受该国政府赠送给A市的贵重礼物，回国后甲隐瞒未报，据为己有

B. 甲与某小型国有全资企业签订承包租赁合同，经营该企业，在经营管理期间，以制造假证明的方式，将该企业5处房产（价值300万元）过户转移到其个人名下

C. A理财公司受某国家机关委托经营、管理社会保险基金，甲在该公司管理社保基金期间，将20万元挪出用于炒期货，营利甚丰；案发之后，甲虽有能力归还但拒不归还

D. 某派出所干警甲某，某日身着警服巡逻。发现一辆无牌照白色天津大发车停放在路边，遂上前查问司机的驾驶证，没想到司机没回话就逃走了。甲某见司机弃车逃走，怀疑此车是偷

〔1〕 ABCD

方鹏刑法讲义

来的，就设法将该车拉回自己家中，并将车喷涂成红色，将车据为己有。后经调查证实该车确系被盗车辆

★二、挪用公款罪：挪作私用

【相关法条】

第384条【挪用公款罪】国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。

【考点精析】

挪用公款罪，是指国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的行为。本罪的法益是职务行为的廉洁性和公款的占有、使用、收益权。

（一）构成要件要点

1. **主体身份（身份犯）**：仅为国家工作人员。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员（非国家工作人员）挪用本单位资金的，认定为挪用资金罪。

2. **利用职务（公务）上的便利**。指利用职务上主管、管理、经营、经手公共财物的权力及方便条件。国有单位领导利用职务上的便利指令具有法人资格的下级单位将公款供个人使用的，也系利用职务上的便利，属于挪用公款行为，构成犯罪的，应以挪用公款罪定罪处罚。

3. **“挪用公款归个人使用”**（挪作私用）［客观不法行为］：**“三私”**。

决定者	公款去向	名义	谋取利益	三私
个人决定	供自然人（本人、亲友等）使用			**去向是私人**
	供其他单位（私有、国有）使用	以个人名义		去向是单位， **私人名义借**
		以单位名义	谋取个人利益	去向是单位， 单位名义借， **为了谋私利**

（1）**去向是私人**。（个人决定）将公款供本人、亲友或者其他自然人使用的。单位集体决定将公款借给自然人的，不属挪用。

（2）**去向是单位，私人名义借**。先挪给个人，（个人决定）以个人名义将公款供其他单位使用的。指个人擅自决定将公款借给自然人；单位集体决定以个人名义将公款借出的，不属挪用。

①“以个人名义”是指挪用人在出借公款时，是以自然人名义出借，而不是以单位名义出借的。“以个人名义”，不能只看形式，要从实质上把握。对于行为人逃避财务监管，或者与使用人约定以个人名义进行，或者借款、还款都以个人名义进行，将公款给其他单位使用的，应认定为“以个人名义”。

②“其他单位”既包括私营单位、合伙单位、民营单位，也包括国有单位。

（3）**去向是单位，单位名义借，为了谋私利**。个人决定以单位名义将公款供其他单位使

用，谋取个人利益的。

①“个人决定”指未经单位集体决策，个人擅自决定。既包括行为人在职权范围内决定，也包括超越职权范围决定。

②“以单位名义”是指挪用人在出借公款时，是以单位名义出借的。如以自然人名义出借，则属前述（2）。

③“谋取个人利益”指出借公款的主观目的是为了个人得到好处。其中的“个人利益”，既包括财产性利益，也包括非财产性利益，但这种非财产性利益应当是具体的实际利益，如升学、就业等。既包括不正当利益，也包括正当利益。“个人利益”不必实际获取，既包括行为人与使用人事先约定谋取个人利益实际尚未获取的情况，也包括虽未事先约定但实际已获取了个人利益的情况。

（4）不属“挪用公款归个人使用”的情形：单位决定、为了单位利益。

①经单位领导集体研究决定，将公款给个人使用；或者单位负责人为了单位的利益，决定将公款给个人使用的，不属“挪用公款归个人使用”，不构成挪用公款罪。上述行为致使单位遭受重大损失，构成其他犯罪的，依照刑法的有关规定对责任人员定罪（如国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，国有公司、企业、事业单位人员失职罪，签订、履行合同失职被骗罪）处罚。

②个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，没有谋取个人利益的，不属“挪用公款归个人使用”，不构成挪用公款罪。触犯其他罪名的，如受贿罪，国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪，以其他犯罪论处。

【经典考题】

2003/2/31. 下列哪些情形，属于挪用公款归个人使用，从而可能构成挪用公款罪？〔1〕

A. 国有公司经理甲将公款供亲友使用

B. 国有企业财会人员乙以个人名义将公款供其他国有单位使用

C. 国家机关负责人丙个人决定以单位名义将公款供其他单位使用，但未谋取个人利益

D. 国有企业的单位领导集体研究决定将公款给私有企业使用

4. **三种用途（主观欲图用于何处）**及构成犯罪的条件［主观责任的量］。

	用途	立法数额	时间	司法数额
挪用公款归个人使用	进行非法活动			3 万
	进行营利活动	数额较大		5 万
	其他活动（生活消费使用）	数额较大	3 个月	5 万

（1）挪用公款归个人使用，进行非法活动。

①用途：进行非法活动。既包括进行犯罪活动，也包括进行一般行政违法活动。例如，挪用公款进行走私、贩毒、赌博、行贿、生产伪劣产品等。

②立法层面上无需数额，当前司法解释中以 3 万为起点。

③不需要时间条件，不受时间限制。

（2）挪用公款归个人使用，进行营利活动+数额较大。

①用途：进行营利活动。营利活动指合法的、可能获利的经营性活动，欲图营利实际未获得利益，也认为是营利活动。营利活动的表现形式通常如：挪用公款用于个人办公司、申报注

〔1〕 AB

册资本、验资，挪用公款存入银行获取利息，用于购买股票、国债、集资入股，挪用公款炒房、炒期货、放贷。挪用公款进行营利活动，所获取的利息、收益等违法所得，应当追缴，但不计入挪用公款的数额。

②需要数额，要求数额较大。

③不需要时间条件，不受时间限制。亦即，即使挪用一会儿、一天，也构成犯罪。例如，国有公司人员将单位公款100万元挪用借给朋友开公司验资之用，上午挪用下午归还，也认定为挪用公款罪。

(3) 挪用公款归个人使用，进行非法活动、营利活动之外的其他活动+数额较大+超过3个月。

①用途：进行非法活动、营利活动之外的其他活动，一般指生活消费使用。例如挪用公款给家里买房子、买车，供子女上学临时借用，借给亲友治病周转等。

②需要数额，要求数额较大。当前司法解释中以5万元为起点。

③需要时间，挪用公款的时间超过3个月。刑法法条措辞为“超过3个月未还”，是指行为人挪用公款后在3个月之内没有归还，也就是说“未还”二字是多余的。挪用公款超过3个月，即使在3个月之后案发之前已经主动归还了本金，也构成挪用公款罪，只不过在量刑时可以从轻处罚或者免除处罚。

挪用公款归还个人欠款的，应当根据产生欠款的原因，分别认定属于挪用公款的何种情形。归还个人进行非法活动或者进行营利活动产生的欠款，应当认定为挪用公款进行非法活动或者进行营利活动。归还个人生活消费产生的欠款，应当认定为挪用公款进行非法活动、营利活动之外的其他活动。

(4) 三种用途在立法原理上系主观用途（主观欲图用于何处）。即行为人主观上计划的用途，而不要求一定客观上实际使用。亦即是行为人“想怎么用”，而不是“实际用了没有”。

①一般情况下，行为人挪用公款后实际使用的，一般根据其实际使用的情况来推断其用途；实际使用时改变原计划用途的，原则上也根据实际使用来确认用途（证据推断规则）。例如，国家工作人员为了购房而挪出公款，但因为房屋涨价而没有购房，于是将公款用于赌博，宜认定为挪用公款进行非法活动。原本打算挪出公款赌博，但因为股市行情好而用于炒股的，宜认定为挪用公款进行营利活动。

②尚未投入实际使用，不能查明挪用人的主观用途具体内容的，以上述（3）的用途认定，即认定为挪用公款归个人使用，进行非法活动、营利活动之外的其他活动，需数额较大，超过3个月，才能构成挪用公款罪。例如，行为人挪出公款，案发时一直没有使用，又没有证据证明其具体用途为何，宜认定为挪用公款归个人使用进行其他活动。

③行为人挪用公款后未实际使用的，有确切证据证明挪用人挪用时主观用途具体内容的，以该用途认定。例如，国家机关的工作人员甲挪用了100万元，放置在家里没有使用，2个月后被发现抓获。如能查明其挪用用途是想开公司，即以挪用进行营利活动认定；如能查明其挪用用途是欲图走私，即以挪用进行非法活动认定。

④对于用途存在认识错误，以主观上认识的用途确定。特别是在挪用公款的共同犯罪中，挪用人与使用人认识的用途不一致时，以各自认识的用途确定用途，以本人认识作为构成犯罪的根据。例如，乙以进行营利活动为名，向国家工作人员甲借用公款，而实际上乙的用途是进行非法活动。则认定甲系挪用进行营利活动，乙系挪用进行非法活动。

5. **对象：公款、特定公物**，不包括一般公物。

（1）公款，包括现金，股票、国库券、债券等有价证券等。

（2）失业保险基金和下岗职工基本生活保障资金。

微博“刑法学人方鹏”：学好真刑法，仗剑走天涯

方鹏刑法讲义

（3）用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款和物。

挪用金融凭证、有价证券用于质押，使公款处于风险之中，与挪用公款为他人提供担保没有实质的区别，符合刑法关于挪用公款罪规定的，以挪用公款罪定罪处罚，挪用公款数额以实际或者可能承担的风险数额认定。

挪用非特定公物归个人使用的，不以挪用公款罪论处。构成其他犯罪的（如滥用职权罪），依照刑法的相关规定定罪处罚。

（二）挪用公款罪的数额认定

1. 挪用公款数额累计计算。多次挪用公款不还，挪用公款数额累计计算。

2. 拆东墙补西墙，以案发时未还的实际数额认定。

3. 多次挪用公款，分别用于非法活动、营利活动与其他活动等不同用途，各项用途均未达到定罪数额的，判断成罪与否可考虑**“向下折算累加”**（非法活动折成营利活动，再折成其他活动），来计算数额。

（1）如3个月内均未归还，累计计算数额时，应当累计至较为轻缓（严重程度：非法活动>营利活动>生活消费）的用途。例如，甲挪用公款1万元用于非法活动，挪用公款2万元进行营利活动，挪用公款3万元进行其他活动，均超过3个月未还。应认定甲挪用公款6万元进行其他活动，超过3个月，成立挪用公款罪。乙挪用公款2万元进行走私非法活动，挪用公款3万元进行营利活动。应认定乙挪用公款5万元进行营利活动，数额较大，成立挪用公款罪。

（2）如3个月内部分归还、部分未归还，则应将归还的部分累计，未归还的部分累计，分别累计至较为轻缓的用途，看对应的用途是否达到成罪条件。例如，丙挪用公款2万元进行营利活动，又挪用公款7万元进行其他活动，拿出其中2万归还之前挪用的，其余超过3个月未还直至案发。应当认定丙挪用公款7万元进行其他活动。

（三）挪用公款罪（不具非法占有目的）与贪污罪（非法占有目的）的关系

1. 区分原理：贪污罪要求行为人具有非法占有目的。行为人在挪用公款之后，如果查明具有非法占有目的（不归还公款的意思），则以贪污罪论处。也就是说，贪污罪可包容评价为挪用公款罪（整体法与部分法的法条竞合关系）。可查明有非法占有目的的，由挪用公款罪“转化”为贪污罪。

2. 证明行为人主观上具有非法占有目的、构成贪污罪的事实依据（证据推断规则）：

（1）携带挪用的公款潜逃的。

（2）挪用公款后采取虚假发票平账、销毁有关账目等手段，使所挪用的公款已难以反映在单位财务账目上，且没有归还行为的。

（3）截取单位收入不入账，非法占有，使所占有的公款难以反映在单位财务账目上，且没有归还行为的。

（4）有证据证明行为人有能力归还所挪用的公款而拒不归还，并隐瞒挪用的公款去向的。

3. 对查明具有非法占有目的的数额，以贪污罪定罪。剩余数额，如符合挪用公款罪的构成要件，认定为挪用公款罪，数罪并罚。例如，行为人挪用100万元炒股，案发后携带10万元潜逃。认定为贪污罪10万元，挪用公款罪90万元，数罪并罚。

4. “挪用公款不退还”（主观上想还）与贪污罪（主观上不想还）。

（1）挪用公款，主观上想还，但因客观原因在一审宣判前不能退还的，仍认定挪用公款罪；如数额巨大，系“挪用公款数额巨大不退还”，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑。

（2）挪用公款，查明行为人主观上不想还的，以贪污论处。

（四）罪数

1. 因挪用公款而索取、收受贿赂（受贿罪），数罪并罚。

方鹏刑法讲义

2. 挪用公款进行非法活动构成其他犯罪的，数罪并罚。

3. 挪用生息公款后将利息据为己有，认定为挪用公款罪一罪（不再另定贪污罪）。所获取的利息、收益等违法所得，应当追缴，但不计入挪用公款的数额。

（五）挪用公款罪的共同犯罪

1. 挪用公款给他人使用，使用人与挪用人共谋，指使或者参与策划取得挪用款的，以挪用公款罪的共犯定罪处罚。

（1）须符合刑法总则中共同犯罪的成立条件，亦即共同故意、共同行为、终了之前加入，才构成共犯。①如果在挪用人已经实施完毕挪用行为挪用出公款之后，使用人明知是挪用的公款提出借用的，不构成挪用公款的共犯。②使用人只是单纯提出要求借用公款，并未要求挪用人使用挪用的非法手段借出公款，是挪用人本人产生挪用犯意的，使用人也不构成挪用公款的共犯。

（2）共同犯罪人不限于使用人。其他具有共同故意，对挪用公款行为有教唆、帮助、共同实行行为的人，也可构成挪用公款的共同犯罪。

（3）使用人具有诈骗故意或者其他犯罪故意，而国家工作人员具有挪用故意。使用人有可能构成他罪，但不影响国家工作人员成立挪用公款罪。例如，甲对国家工作人员乙许以高额回报，让乙挪用公款100万元，谎称用于炒股，乙挪出公款后交给甲，甲卷款潜逃。甲构成诈骗罪（与挪用公款罪的教唆犯竞合），乙构成挪用公款罪。

2. 各共同犯罪人，对于挪用公款的用途认识不一致的，应依据本人认识来确定挪用用途。例如，甲教唆国家工作人员乙挪用公款300万元，谎称自己买房之用，乙信以为真而挪用，实际上甲用于贩毒。则乙认定为挪用公款进行其他活动（生活消费），需数额较大、3个月才能构成犯罪；甲认定挪用公款进行非法活动，无需数额（司法数额为3万元）、时间，即可构成犯罪。

（六）挪用公款罪，与挪用资金罪、挪用特定款物罪

1. **挪用资金罪**（与挪用公款罪对比）：一般法与特别法（身份特别）。

2. **挪用特定款物罪**（与挪用公款罪、挪用资金罪对比）：挪作其他公用。

罪名	主体身份	核心构成要素				关系
挪用公款罪	国家工作人员	利用公务便利	**挪作私用**	本单位款项（及特定款物）	量的要素	特别法（身份特别）
挪用资金罪	单位人员	利用职务便利				一般法
挪用特定款物罪	责任人员		**挪作其他公用**	特定款物	重大损害	挪作其他公用

【考点归纳】

★1. **挪作私用**有三种（三私）：去向私人；去向单位、私人名义；去向单位、单位名义、为谋私利。

★2. **成罪条件**有三类：非法活动数额3万元，营利活动数额5万元，其他（生活消费）数额5万元时间3个月。

★3. **教唆、帮助挪用**：不法层面（挪作私用）上是共犯；共犯各怀鬼胎，各自主观确定用途（主观责任）。

微博“刑法学人方鹏”：学好真刑法，仗剑走天涯

★4. **与贪污罪区分**：对有非法占有目的（携款潜逃、平账、不入账、有能力归还而不还）的数额定贪污，其他数额定挪用。

【经典考题】

【2025/客A/卷一/仿31：贪污罪VS挪用公款罪、受贿罪】甲系某国有公司董事长，乙系某民营公司的民营企业家。乙为了获取甲所在国有公司的合作项目，与甲达成私下约定：甲利用职务便利将该项目交由乙的公司承接；同时，甲将其个人所有的300万元款项出借给乙的公司，双方约定借款到期后，乙的公司需按法定贷款利率三倍的标准向甲支付利息。后来，乙的公司因经营不善破产，无力偿还甲的个人借款及高额利息。甲遂再次利用职务便利，将本单位（国有公司）的300万元公款直接借给乙的公司，并要求乙立即用该笔公款归还乙的公司欠甲的300万元借款。关于甲的行为定性，下列说法正确的有？（多选）[1]

A. 甲将自己的个人财产300万元借给乙的公司，对于约定收取的高额利息，构成受贿罪

B. 甲将300万元公款借给乙的公司，让乙偿还其公司对甲的债务，构成贪污罪

C. 甲构成贪污罪、受贿罪，应当数罪并罚

D. 甲将300万元公款借给乙的公司，构成挪用公款罪

2021/客/卷一/仿21. 乙为某国有企业出纳，甲对乙说："你挪用300万给我炒股，2个月后还你，挣的100万我们平分"。乙遂挪用300万元公款打到甲指定银行账户上。甲收到款后，将100万用于炒股，200万用于自购房屋。2个月后，甲将300万元归还给乙，乙归还单位账户。关于甲乙二人所犯挪用公款罪的数额，以下说法正确的是？[2]

A. 甲乙都是100万元　　B. 甲100万元，乙300万元

C. 甲300万元，乙100万元　　D. 甲乙都是300万元

【2025/客A/卷一/仿32：挪用公款罪、贪污罪、犯罪数额】甲系某国有公司出纳（国家工作人员），利用职务便利挪用本单位公款100万元用于炒股，后该100万元全部亏损。为弥补挪用公款造成的损失，甲又利用职务便利以非法占有为目的贪污本单位120万元公款，将其中100万元用于归还此前挪用的公款。关于甲的行为性质，下列说法正确的有？（单选）[3]

A. 甲使用贪污款项归还挪用的公款，故不构成挪用公款罪，仅构成贪污罪，犯罪数额为120万元

B. 甲的贪污罪的犯罪数额为20万元，挪用公款罪的犯罪数额为100万元，应当数罪并罚

C. 甲的贪污行为是由挪用公款罪引起的，二者属于牵连犯

D. 甲所犯贪污罪金额为120万元，所犯挪用公款罪金额100万元，但最终只需追缴120万元即可

【拓展习题】

以下哪些情况构成挪用公款罪？[4]

A. 某村村主任甲，在受乡政府委托发放救灾专用大米期间，利用管理救灾公物的便利，个人决定以个人名义将100吨大米（价值45万元）借与本地一粮油公司出售，甲未谋取个人利益

B. 某县县长乙，与县领导集体研究后将该县下岗职工基本生活保障资金100万元挪出，以该县政府的名义借给一家证券公司，乙得到好处费10万元

C. 丙与某国有公司签订承包租赁合同，承包经营该公司的购销部，在经营该部门期间，未经该公司议事程序，擅自将公司拨付的流动资金50万元挪用进行贩毒

---

〔1〕ABC　〔2〕B　〔3〕D　〔4〕AD

方鹏刑法讲义

D. 丁与某国有全资企业聘用的会计人员 D 某（企业编制）是同学，丁指使 D 某将该企业的购货款偷偷盗出，用于合伙投资公司，对于丁的行为

三、私分国有资产罪

【相关法条】

第 396 条第 1 款【私分国有资产罪】国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

【考点精析】

私分国有资产罪是指国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，违反国家规定，以单位名义将国有资产集体私分给个人，数额较大的行为。这里的“国有资产”指归国家所有或全民所有的资产。私分国有资产罪成罪的原理在于：国有单位将其占有的归国家（大集体）所有的资产，私分给本单位个人（小集体），从而侵犯国有资产所有权。实际上就是一种单位实施的贪污行为。

私分国有资产罪：国有单位，以单位名义，将国有资产，集体私分给个人
私分国有资产罪与集体贪污的区分：单位行为 VS 个人行为。（1）私分的人员的多少；（2）单位集体研究与否；（3）单位内部员工知情与否
单位集体私分定**私分国有资产罪**，私分给少数个人定**共同贪污**

1. **主体：国有单位**。本罪是纯正单位犯罪，主体为国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体（国有单位）。

既然本罪是单位犯罪，就要求符合单位犯罪的一般要求，亦即以单位名义，为单位（单位或单位大部分员工）利益，经单位集体研究决定。如有一项不符合，例如，没有分配给单位大部分员工而只是分配给少部分员工，没有经单位集体研究决定而是个人私自决定，都应认定为个人犯罪（贪污罪），而不认为是单位犯罪（私分国有资产罪）。

2. **对象：国有资产**。

国有资产即国家所有的财产，即国有单位占有、使用的，依法确认为国家所有的财产。包括流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

3. 集体私分给个人：未经国家同意而只经单位集体研究决定，将国有资产分配给单位的所有成员或者多数人。

4. 本罪采取单罚制。只对直接负责的主管人员和其他直接责任人员追究刑事责任，对单位不判处罚金。

5. **私分国有资产罪与集体贪污的区分**（单位行为 VS 个人行为）。

（1）私分的人员的多少。将国有资产分配给单位的所有成员或者多数人的，构成私分国有资产罪；分配给少数人甚至仅在领导班子成员内部私分的，构成贪污罪（《刑事审判参考》第 313 号：杨代芳贪污、受贿案）。

（2）单位集体研究与否。单位集体研究分配给多数人的，构成私分国有资产罪；个人决定私分给少数人的，构成贪污罪。

（3）单位内部员工知情与否。单位内部员工知情，在单位内部公开分配，分配给多数人的，构成私分国有资产罪；单位内部员工不知情，秘密分配，分配给少数人的，构成贪污罪。

微博“刑法学人方鹏”：学好真刑法，仗剑走天涯

方鹏刑法讲义

（4）对于钱款私分给单位员工，部分钱款侵吞为己有，可以进行区分的，可以数罪并罚。

【经典考题】

2008/4/2. 涂某系某市国有黄河商贸公司的经理，顾某系该公司的副经理。2005 年，黄河商贸公司进行产权制度改革，将国有公司改制为管理层控股的股份有限公司。其中，涂某、顾某及其他 15 名干部职工分别占 40%、30%、30%股份。在改制过程中，国有资产管理部门委托某资产评估所对黄河商贸公司的资产进行评估，资产评估所指派周某具体参与评估。在评估时，涂某与顾某明知在公司的应付款账户中有 100 万元系上一年度为少交利润而虚设的，经涂某与顾某以及公司其他领导班子成员商量，决定予以隐瞒，转入改制后的公司，按照股份分配给个人。当周某发现了该 100 万元应付款的问题时，公司领导班子决定以辛苦费的名义，从公司的其他公款中取出 1 万元送给周某。周某收下该款后，出具了隐瞒该 100 万元虚假的应付款的评估报告。随后，国有资产管理部门经研究批准了公司的改制方案。在尚未办理产权过户手续时，涂某等人因被举报而案发。

【问题】涂某与顾某构成贪污罪还是私分国有资产罪？为什么？

第三节　贿赂犯罪

收钱方		送钱方	
国家工作人员	**受贿罪（普通；斡旋）**	自然人→国工	**行贿罪**
		单位→国工	**单位行贿罪**
国工、离职国工近亲属、关系密切人；离职国工	**利用影响力受贿罪**	自然人→国工、离职国工近亲属、关系密切人；离职国工	**对有影响力的人行贿罪**
国家机关、国有单位	**单位受贿罪**	自然人、单位→国家机关、国有单位	**对单位行贿罪**
非国家工作人员	**非国家工作人员受贿罪**	自然人、单位→非国工	**对非国家工作人员行贿罪**
自然人→介绍自然人、单位→向国工自然人：**介绍贿赂罪**			

★一、受贿罪：权钱交易

【刘志军受贿案〔1〕】2004 年至 2011 年，被告人刘志军利用担任铁道部部长职务上的便利，接受博宥投资管理集团有限公司法定代表人丁羽心的请托，为丁羽心及其亲属实际控制的公司获得铁路货物运输计划、获取经营动车组轮对项目公司的股权、运作铁路建设工程项目中标、解决企业经营资金困难等事项提供帮助。2007 年 12 月，铁道部政治部原主任何洪达因涉嫌严重违纪被调查，刘志军担心自己收受何洪达贿赂的事情暴露，指使丁羽心疏通关系帮助何洪达逃避查处。为此，丁羽心先后给予谎称有能力运作此事的刘琳等人共计人民币 4400 万元。2008 年至 2010 年，刘志军为了给自己职务调整创造条件，指使丁羽心疏通关系，为此，丁羽心于 2010 年下半年给予谎称有能力运作此事的于振勇 500 万元。丁羽心将上述钱款支付情况

〔1〕“刘志军受贿、滥用职权案”，载《中华人民共和国最高人民检察院公报》2013 年第 6 期。

方鹏刑法讲义

均告知了刘志军。

【问题】刘志军、丁羽心的行为如何认定？

【考点精析】

受贿罪，包括普通受贿罪、斡旋型的受贿罪。受贿罪侵害的法益是职务行为的不可收买性。受贿罪的本质也就是权钱交易。受贿罪的构成，主体身份要求是国家工作人员，需利用职务（职权、职位）上的便利，对象是财物。以下分别对受贿行为的形式、贿赂对象的形式等予以讲解。

（一）受贿行为的形式

受贿行为的表现形式，可分为普通受贿（索取贿赂、收受贿赂）、斡旋型受贿。另外，司法解释规定的离职后受贿（离职后收钱、在职时有约定）、不作为形式的受贿，是对前述刑法规定的解释和提示。

1. **普通受贿**（索取贿赂、收受贿赂）：出卖自身职权。

第385条第1款【普通受贿罪】国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物的，或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，是受贿罪。

索取贿赂（主动要）	无需“为他人谋取利益”	
收受贿赂（被动收）	需要“为他人谋取利益”（正当、不正当）	客观构成要件要素（客观上承诺即可） 1. 实际或者承诺为他人谋取利益的； 2. 明知他人有具体请托事项的； 3. 履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受； 4. 索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物，可能影响职权行使

（1）索取贿赂，无需为他人谋取利益。

索取贿赂，即国家工作人员利用职务便利，主动向对方要求、索要、勒索贿赂。索取贿赂只需要利用职务上的便利就成立受贿罪，不要求“为他人谋取利益”的要素。

（2）收受贿赂，需为他人谋取利益。

收受贿赂，指对方（行贿者）提出给予贿赂的约定，国家工作人员被动接受行贿者给予的贿赂。收受贿赂的，只有具备“为他人谋取利益”要素，才成立受贿罪。

其一，“为他人谋取利益”是客观构成要件要素。

只要行为人作出了为他人谋取利益的承诺，为他人谋取利益这一客观要件就已经具备。而无论行为人是否心中真的想着要为他人谋取利益；无论行为人之后是否实施了为他人谋取利益的举动或努力；无论最终是否为他人谋取到了利益。

其二，“为他人谋取利益”内容的最低要求是：承诺为他人谋取利益。包括：

①实际或者承诺为他人谋取利益的。

②明知他人有具体请托事项的。

③履职时未被请托，但事后基于该履职事由收受。

④索取、收受具有上下级关系的下属或者具有行政管理关系的被管理人员的财物，可能影响职权行使。

其三，需要注意以下几点：

①承诺既可以是明示的，也可以是暗示的。当他人主动行贿并提出为其谋取利益的要求后，国家工作人员虽未明确承诺，但只要不予拒绝，就应当认为是一种暗示的承诺。

②承诺既可以是真实的，也可以是虚假的。国家工作人员主观上并不打算为他人谋取利

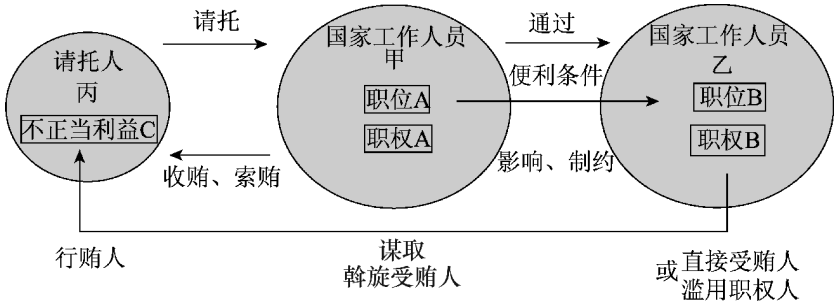
方鹏刑法讲义

益，却在客观上虚假承诺要利用本人的职务为他人谋取利益，也构成受贿（此时受贿可以包容诈骗）。当然，如行为人没有为他人谋取利益的职权与职务条件的，应当认定为诈骗罪。

③承诺谋取的利益，既包括正当利益，也包括不正当利益。

2. **斡旋型受贿**：出卖职位便利条件（打招呼）。

第388条【斡旋型的受贿罪】国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的，以受贿论处。



国家工作人员利用本人职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财物或者收受请托人财物的以受贿论处，被称为斡旋受贿。斡旋受贿的例子如：请托人丙给某县公安局局长甲送钱10万，请求甲给该县税务局局长乙说情打招呼，为其非法减免税款。甲利用自己公安局局长的职位，使乙为丙非法减免税款，则甲构成受贿罪（斡旋受贿）。如果乙也收受了钱财，则乙也构成受贿罪（直接受贿）。如果乙没有收受钱财，则乙也构成徇私舞弊不征、少征税款罪。丙构成行贿罪。

主体身份：国家工作人员	要有“官位”
利用本人职权或者地位形成的便利条件	本人利用“官位影响”，与被招呼的办事官员之间具有职位影响、工作关系。包括影响关系（同级同事关系、下上级关系）、制约关系（上下级关系），工作联系
通过其他国家工作人员职务上的行为	不是直接利用本人职权，而是直接利用本人“官位”、间接利用他人职权
为请托人谋取不正当利益	承诺即可。内容上，或程序上不正当，或谋取竞争优势
索取或收取请托人财物	利用“官位影响”收钱，也是权钱交易

（1）主体身份是国家工作人员。受贿罪（普通受贿、斡旋受贿）的主体都是国家工作人员。

（2）利用本人职权或者地位形成的便利条件。这里“利用本人职权或者地位形成的便利条件”，通俗地理解，就是利用本人的“官位影响”给办事官员“打招呼”。具体而言包括：

①影响关系。单位内部不同部门的国家工作人员之间、上下级单位没有职务上隶属、制约关系的国家工作人员之间。例如，A县工商局长向A县公安局局长打招呼（同事之间）；县基层法院法官向市中级人民法院法官打招呼（下上级之间）。

②工作联系。有工作联系的不同单位的国家工作人员之间。例如，A县县委书记向B县县长打招呼。

③制约关系。职位上虽有隶属、制约关系，但职务上没有隶属、制约关系的国家工作人员之间。即上级国家工作人员甲对下级国家工作人员乙有人事管辖权，但对下级国家工作人员管理的事务没有管理权限之间。例如，A省省长向该省辖市税务局某科员打招呼（上下级之间）。

总之，同事关系、工作关系、下上级关系、上下级关系，都可认定为具有便利条件。

（3）通过其他国家工作人员职务上的行为。

斡旋受贿不是国家工作人员就自身的职务行为索取或者收受贿赂，而是利用国家工作人员的职权或者地位形成的便利条件，就其他国家工作人员的职务行为进行斡旋，使其他国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取不正当利益，从而索取或者收受贿赂。由此可以认为，普通受贿（直接受贿）是“出卖自身职权”，而斡旋受贿是“出卖职位便利条件”。

如果国家工作人员本人对某项事务具有主管、负责、承办的职权，其在索取收受贿赂之后，令其下属经办此项事务；或者担任单位领导职务的国家工作人员，其在索取收受贿赂之后，令其下级部门的国家工作人员经办此项事务，为他人谋取利益的。都不属于斡旋受贿，而应当直接适用《刑法》第 385 条，以普通受贿（直接受贿）罪论处。

（4）为请托人谋取不正当利益。

该要素为客观要素，只需承诺即可。亦即，行为人只要客观上承诺为请托人谋取该不正当利益即可构成斡旋受贿；而无需主观上有谋利意图，或者实施了谋取利益的努力行为，也无需谋取到了不正当利益。为请托人谋取正当利益的，不构成斡旋受贿。

（5）索取或收取请托人财物。受贿罪的本质是权钱交易，故行为人需索取或收取财物，作为出卖职位便利条件对价，才能构成受贿罪。斡旋受贿也是一种权钱交易，虽不直接利用职权，但出卖职位影响。

【经典考题】

2004/2/59. 甲的女儿 2003 年参加高考，没有达到某大学录取线。甲委托该高校所在市的教委副主任乙向该大学主管招生的副校长丙打招呼，甲还交付给乙 6 万元现金，其中 3 万元用于酬谢乙，另 3 万元请乙转交给丙。乙向丙打了招呼，并将 3 万元转交给丙。丙收下 3 万元，并答应尽量帮忙，但仍然没有录取甲的女儿。1 个月后，丙的妻子丁知道此事后，对丙说：“你没有帮人家办事，不能收这 3 万元，还是退给人家吧。”丙同意后，丁将 3 万元退给甲。关于本案，下列哪些说法是错误的？〔1〕

A. 乙的行为成立不当得利与介绍贿赂罪

B. 丙没有利用职务上的便利为他人牟取利益，所以不成立受贿罪

C. 丙在未能为他人牟取利益之后退还了财物，所以不成立受贿罪

D. 丁将 3 万元贿赂退给甲而不移交司法机关，构成帮助毁灭证据罪

3. 离职后收钱、在职时有约定：以约定行为作为受贿行为。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》第 10 条：国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益之前或者之后，约定在其离职后收受请托人财物，并在离职后收受的，以受贿论处。国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益，离职前后连续收受请托人财物的，离职前后收受部分均应计入受贿数额。

离职后收钱	在职时约定：受贿罪	在职时无约定：不构成受贿罪
在职时收钱	事先约定：受贿罪	事先无约定（事后知情）：受贿罪

（1）离职后（无身份）收钱，需在职时（有身份）有约定，才构成受贿罪。这是对受贿行为的提示性解释，亦即，将在职时实施的约定收钱行为，解释为受贿行为；将离职后的收钱，认为是对之前受贿行为的兑现、延期支付。由此，行为人实施约定收钱行为时具有国家工

〔1〕 ABCD

作人员身份，可构成受贿罪。相反，如果国家工作人员在职为请托人谋利时，没有收受贿赂的约定；是国家工作人员在离职之后向请托人索要，或者请托人主动给予钱财的，不能构成受贿罪。

（2）**在职时（有身份）收钱，无需事前有约定，均构成受贿罪**。另应当注意的是：如果国家工作人员在职时收受请托人财物，无论其事前有约定（事前受贿），还是事前无约定（事后受贿），只要其在收受财物时知财物系其职务的不正当对价，即可认定构成受贿罪。因为行为人实施收钱行为时具有国家工作人员身份。

4. **不作为受贿**：明知特定关系人收贿而不退还。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第16条第2款："特定关系人索取、收受他人财物，国家工作人员知道后未退还或者上交的，应当认定国家工作人员具有受贿故意。"这是对不作为受贿行为、受贿故意的提示性解释。反义解释，如果国家工作人员知情后退还，或者对收受财物不知情，就不能构成受贿罪。

（二）受贿罪的对象：财物（贿赂）

1. **财物（贿赂）：货币、物品、财产性利益。**

受贿罪的对象是"财物"，即贿赂，包括货币、物品和财产性利益。财产性利益包括可以折算为货币的物质利益如房屋装修、债务免除等，以及需要支付货币的其他利益如会员服务、旅游等。亦即，一切可以折算为货币，或者支付货币购买的物品、服务、利益等，均可认定为贿赂。

2. **收受回扣型受贿：回扣、手续费形式的贿赂。**

第385条第2款【收受回扣型的受贿罪】国家工作人员在经济往来中，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，以受贿论处。

财物	**回扣、手续费**	以"回扣、手续费"为名义，实为职务行为的不正当对价
职务便利	**在经济往来中**	依据职务参与的经济管理活动，以及其他经济交往活动
受贿	**归个人所有**	对方单位给予个人的，最后归个人私有

收受回扣型的受贿罪（经济受贿），是对贿赂形式的提示性规定，即将各种名义的回扣、手续费，认定为贿赂。

（1）回扣、手续费。这里的"回扣、手续费"应当指账外"暗扣"，即卖方暗中给予国家工作人员的金钱、实物或者其他物质利益，以及以"回扣、手续费"为名义，实为职务行为不正当对价的款项。

（2）经济交往。指国家工作人员依据职务参与的国家经济管理活动，以及其他经济交往活动。

（3）违反国家规定。指违反全国人民代表大会及其常委会制定的法律，国务院制定的行政法规和行政措施、发布的决定和命令。例如《反不正当竞争法》（2025年修正）第8条第1、3款规定："经营者不得采用财物或者其他手段贿赂下列单位或者个人，以谋取交易机会或者竞争优势：（一）交易相对方的工作人员；（二）受交易相对方委托办理相关事务的单位或者个人；（三）利用职权或者影响力影响交易的单位或者个人。经营者在交易活动中，可以以明示方式向交易相对方支付折扣，或者向中间人支付佣金。经营者向交易相对方支付折扣、向中间人支付佣金的，应当如实入账。接受折扣、佣金的经营者也应当如实入账。"由此，账外暗中收受回扣是违法的，应以受贿论处。

（4）归个人所有。回扣、手续费归个人所有，中饱私囊或者少数人私分的，个人构成受

方鹏刑法讲义

贿罪。如果对方给予的回扣、手续费，是给予单位的，个人不构成受贿罪。如系商业优惠，则无罪；如符合单位受贿罪构成要件的，应对单位以该罪论处。如个人将对方给予单位的财物私吞，可涉嫌贪污罪。

3. **变相受贿**：财产性利益。

受贿罪中“贿赂”的形式通常表现为财物（货币、物品），还可以表现为财产性利益，“权钱交易”的行为也常常以合法的外表予以掩饰。为此，《最高人民法院、最高人民检察院关于办理受贿刑事案件适用法律若干问题的意见》对一些特殊形式的受贿进行了规定。本书概称为“变相受贿”。

交易形式的受贿	以明显低于市场的价格向请托人购买物品的；以明显高于市场的价格向请托人出售物品的；其他交易形式非法收受请托人财物
收受干股形式的受贿	未出资而获得干股
以开办公司等合作投资名义的受贿	由请托人出资，“合作”开办公司或者进行其他“合作”投资
委托理财型受贿	以委托请托人投资证券、期货或者以其他委托理财的名义，未实际出资而获取“收益”；或者虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益
赌博型受贿	表面上是赌博，实际上是收钱
挂名领薪型受贿	要求或者接受请托人以给特定关系人（国家工作人员的近亲属、情妇情夫等有共同利益关系的人）安排工作为名，使特定关系人不实际工作却获取所谓薪酬
名借实给（汽车、房产）型受贿	收受请托人房屋、汽车等物品，未变更权属登记或者借用他人名义办理权属变更登记

（三）受贿罪的既遂：取得控制说（一般3万以上）

1. 受贿罪以取得、控制贿赂（事实控制、法律控制）为既遂。

2. 控制了有价票证可随时兑现，即认为是既遂。例如，收受了他人交付的转账支票后，还没有提取现金的；收受购物卡后，即使还没有购物；收受银行卡后，还没有实际使用的，原则上都认为是既遂，数额以卡上记载的数额认定。

原则上，依据《最高人民法院最高人民检察院关于办理商业贿赂刑事案件适用法律若干问题的意见》，第8条“收受银行卡的，不论受贿人是否实际取出或者消费，卡内的存款数额一般应全额认定为受贿数额”。但是，该司法解释仍需按“实际控制”标准进行具体再解释。

（1）行贿人提供了完全充分的信息，足以保证受贿人完全取出卡内存款或者消费，但由于银行方面的原因如技术故障，或者由于受贿人自身操作问题（如记错密码），导致暂时不能取出存款或者消费的，仍应认定为受贿既遂。这是因为，行贿人将银行卡送给国家工作人员并告知其相关信息后，银行卡所对应的财物控制权便已转移。国家工作人员随时可以取出存款或者刷卡消费。银行出现技术故障、个人出现操作失误等原因，并不能从实质上阻碍国家工作人员对财物的控制权。当这些障碍排除后，国家工作人员便可以正常使用银行卡。

（2）行贿人送卡后抽回存款或者以挂失等方式阻碍受贿人取款或者消费的，受贿数额以受贿人已经取款或消费的数额计算。受贿人因行贿人的上述行为未能取出或消费的部分，按受贿未遂论处。这是因为，国家工作人员收受银行卡后，虽已取得财物的控制权，但由于银行卡是行贿人以自己名义办理的，其亦可变更密码、挂失或者抽回卡内钱款，导致国家工作人员丧失对卡内剩余钱款的实际控制权，因此对剩余部分应以未遂论处。

方鹏刑法讲义

3. 名借实给（房屋、汽车）型的受贿中，收受请托人房屋、汽车，未变更权属登记的，不影响受贿的认定，也不影响受贿既遂的成立。

【经典考题】

2023/客A/卷一/仿19. 甲为了谋取不正当利益，向国家工作人员乙行贿100万，给了乙一张甲的银行卡并告知密码。第二天，甲在网上银行将银行卡中的钱款性质变更为定期存款，只有用甲的身份证才能取出。截止到案发，乙都一直无法取出卡里面的钱款。关于本案以下说法正确的有？〔1〕

A. 乙构成受贿罪既遂　　B. 乙构成受贿罪未遂

C. 甲构成行贿罪既遂　　D. 甲对乙构成盗窃罪

（四）及时退还、贿赂赃物的处分

1. 及时退还、悔罪退赃问题。

“及时退还或上交”	指行为人主观上没有受贿故意	不是受贿
为掩饰犯罪而退赃	行为人受贿时主观上有受贿故意	系受贿罪既遂
悔罪、事未办成而退赃		

（1）国家工作人员收受请托人财物后及时退还或者上交的，不是受贿。（2）国家工作人员受贿后，因自身或者与其受贿有关联的人、事被查处，为掩饰犯罪而退还或者上交的，不影响认定受贿罪。

2. 国家工作人员出于贪污、受贿的故意，非法占有公共财物、收受他人财物之后，将赃款赃物用于单位公务支出或者社会捐赠的（系受贿既遂后对赃物的处分行为），不影响贪污罪、受贿罪的认定。

（五）受贿罪的罪数

1. 因受贿而进行其他违法活动构成其他罪的，一般依照数罪并罚的规定处罚。

2. 国家机关工作人员收受贿赂并实施渎职犯罪，同时构成受贿罪的，除刑法另有规定外（徇私枉法罪，民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定滥用职权罪），以渎职犯罪和受贿罪数罪并罚。

3. 国家机关工作人员收受贿赂，并实施徇私枉法罪，民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定滥用职权罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

【考点归纳】

★1. 索贿无需谋利，收贿需要**谋利**；客观承诺即可，无需实际行动，无需真想谋利。

★2. 出卖“官位”影响，通过其他国家工作人员，谋取不当利益，构成**斡旋受贿**。

★3. 在职时谋利、约定（以约定时为行为时）离职后收钱，也构成受贿。

★4. 不作为受贿。明知特定关系人收贿而不退还，也成立**受贿**。不知特定关系人收贿，关系人可涉嫌利用影响力受贿。

5. **贿赂**（财物）包括货币、物品和财产性利益，只要可折算为货币，均为贿赂。

6. 无受贿故意及时退还，不是受贿；有受贿故意事后退赃，仍为既遂。

7. 受贿既遂后将赃物用于公务、捐赠，不影响犯罪成立。

〔1〕 B

方鹏刑法讲义

【经典考题】

2003/2/38. 下列关于受贿罪的说法哪些是不正确的？〔1〕

A. 甲系地税局长，1993 年向王某借钱 3 万元。1994 年王某所办企业希望免税，得到甲的批准，王某当时就对甲说："上次借给你的钱就不用还了，算我给你的感谢费"。但甲始终不置可否。2003 年 5 月甲因其他罪被抓获时，主动交待了借钱不还的事实。甲不构成受贿罪

B. 乙的妻子在乡村小学教书，乙试图通过关系将其妻调往县城，就请县公安局局长胡某给教育局局长黄某打招呼，果然事成。事后，乙给胡某 2 万元钱，胡某将其中 1 万元给黄某，剩余部分自己收下。本案中，黄某构成受贿罪、胡某构成介绍贿赂罪、乙构成行贿罪

C. 丙为贷款而给某（国有）银行行长李某 5 万元钱，希望在贷款审批时多多关照。李某收过钱，点了点头。但事后，在行长办公会上，由于其他领导极力反对发放此笔贷款，丙未获取分文贷款资金。李某虽然收受他人财物，但由于没有为他人谋取利益，所以不构成受贿罪

D. 丁系工商局局长，1995 年在对赵某所办企业进行年检时，发现该企业并不完全符合要求，就要求其补充材料。在某些主要材料难以补齐的情况下，赵某多次找到丁，希望高抬贵手。丁见赵某开办企业也不容易，就为其办理了年检手续，但未向赵某提出任何不法要求。2001 年丁退休后欲自己开办公司，就向赵某提出：6 年前自己帮助了赵某，希望赵某给 6 万元作为丁自己公司的启动资金，赵某推脱不过，只好给钱。丁应当构成受贿罪

【拓展习题】

被告人潘某，原系某市某区工业委员会书记。2003 年 8、9 月间，潘某利用其担任的职务便利，为 A 房地产开发有限公司总经理陈某低价获取 100 亩土地等提供帮助。于 9 月 3 日分别以其亲属名义与陈某共同注册成立 C 公司，以"开发"上述土地。潘某既未实际出资，也未参与该公司经营管理。2004 年 6 月，潘某以参与利润分配名义，收受 C 公司"分红"480 万元。（事实一）

2004 年上半年，潘某为 B 发展有限公司（总经理为许某）受让 D 项目减免税款提供帮助，而给该区税务局长王某打电话说情，使 B 公司得到违法少交税款 100 万元。事后，B 公司让潘某帮忙转给王某 10 万元"感谢费"，王某收受。后来，潘某在购买 B 发展有限公司开发的一处房产时，该房价含税费原本为 120 万元，但 B 公司总经理许某表示可以为潘某"打五折"，潘某遂支付 60 万元购买该房产。2006 年 4 月，潘某从一内情人处知悉了有人举报此事的情况，遂补还给许某 60 万元。在检察机关正式立案前，许某向检察机关投案并如实交待了案情事实，并揭发了潘某，使得本案案发。（事实二）〔2〕

【问题】

1. 对于事实一，潘某是否构成犯罪，构成何罪？

2. 对于事实二，潘某、王某构成何罪？是否属于中止？

3. 许某承担何罪的责任？是否成立立功？如何处罚？

★二、利用影响力受贿罪；对有影响力的人行贿罪

【相关法条】

第 388 条之一【利用影响力受贿罪】国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，通过该国家工作人员职务上的行为，或者利用该国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为请托人谋取不正当利益，索取请托人财

〔1〕 ABCD

〔2〕 根据最高人民法院指导案例 3 号"潘玉梅、陈宁受贿案"改编。

方鹏刑法讲义

物或者收受请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处七年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人，利用该离职的国家工作人员原职权或者地位形成的便利条件实施前款行为的，依照前款的规定定罪处罚。

第390条之一【对有影响力的人行贿罪】为谋取不正当利益，向国家工作人员的近亲属或者其他与该国家工作人员关系密切的人，或者向离职的国家工作人员或者其近亲属以及其他与其关系密切的人行贿的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处七年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

【考点精析】

<table>
<tr><td>收钱者</td><td colspan="4"></td><td>送钱者</td></tr>
<tr><td rowspan="3">利用影响力受贿罪</td><td>国家工作人员的近亲属或者关系密切的人</td><td>利用国工职务或利用便利条件</td><td rowspan="3">为请托人谋取不正当利益</td><td rowspan="3">索取或收受请托人财物数额较大或有较重情节</td><td rowspan="3">对有影响力的人行贿罪</td></tr>
<tr><td>离职的国家工作人员</td><td>利用原职权或利用便利条件</td></tr>
<tr><td>离职的国家工作人员的近亲属或者关系密切的人</td><td>利用离职国工原职权或利用便利条件</td></tr>
</table>

利用影响力受贿罪（收钱者），大体上是指国家工作人员、离职国家工作人员的“身边人”（近亲属、关系密切的人）以及离职国家工作人员，利用国家工作人员的职务、离职国家工作人员的原职权，或者利用其职权或原职权地位形成的便利条件，为请托人谋取不正当利益，收受、索取请托人财物，数额较大或者有其他较重情节的行为。具体可将利用影响力受贿罪的情形分为上述表格的三种情形。对合行为人（送钱者）也规定为犯罪，称为“对有影响力的人行贿罪”。

（一）对利用影响力受贿罪关键构成要素的解释

1. **近亲属**。指夫、妻、父、母、子、女、同胞兄弟姊妹。

2. **关系密切的人**。指与国家工作人员、离职的国家工作人员人身关系密切的人，或者具有其他方面的利益的人。难以从关系的形式上予以限定，需从实质层面即是否“足以施加影响”方面进行解释。只要能够影响国家工作人员或者离职的国家工作人员，利用其职权或者地位形成的便利条件的人，均可认定为关系密切的人。例如，情人关系、恋人关系、前妻前夫关系、密切的上下级关系（如国家工作人员的秘书、司机等）等。

3. **两种利用职务的方式**：（1）通过国家工作人员职务上的行为，即直接利用国家工作人员职务；（2）利用国家工作人员、离职的国家工作人员职权或者地位形成的便利条件，即利用国家工作人员、离职的国家工作人员对办事的其他国家工作人员的影响、制约，通过其他国家工作人员职务，进行斡旋谋利。

4. **须为请托人谋取不正当利益**，才构成利用影响力受贿罪。谋取正当利益的，不能构成本罪。

5. **对合犯**。国家工作人员的关系密切的人、离职的国家工作人员、离职的国家工作人员

方鹏刑法讲义

的关系密切的人（收钱者）可构成利用影响力受贿罪，被利用的国家工作人员（不知收钱的被利用者）可能涉嫌滥用职权类犯罪，给予财物的请托人（送钱者）可构成对有影响力的人行贿罪。

（二）利用影响力受贿罪，与受贿罪共犯、受贿罪的区别

1. **近亲属、关系密切的人**：利用影响力受贿罪与受贿罪共犯的区别。有通谋为受贿罪共犯，无通谋为利用影响力受贿罪。

【《刑事审判参考》第1143号：罗菲受贿罪[1]】 罗菲（女）原系中国铁路文工团歌舞团歌唱演员，明知广州中车铁路机车车辆销售租赁有限公司等公司法定代表人杨建宇给予其财物，是为讨好其情夫张曙光（原铁道部运输局局长），以获得张曙光利用职务便利提供帮助，仍在北京、香港等地，多次收受杨建宇给予的折合人民币157.686万元的财物，并征得张曙光同意或者于事后将收财一事告知张曙光。为此，张曙光为杨建宇的公司解决蓝箭动车组租赁到期后继续使用及列车空调设备销售等问题提供了帮助。

【问题】 罗菲、张曙光的行为如何认定？

	有无受贿通谋	国家工作人员	关系密切人
国家工作人员的近亲属或者关系密切的人	与国家工作人员对收受、索取财物事有通谋	受贿罪正犯	**受贿罪共犯**
	无通谋	滥用职权犯罪	**利用影响力受贿罪**

国家工作人员的近亲属或者关系密切的人，收受请托人财物，为请托人谋取不正当利益。

（1）如关系密切的人与国家工作人员有通谋，亦即国家工作人员知情收受财物一事，并且承诺为请托人谋取不正当利益，对于收受财物一事与关系密切的人有意思联络。则国家工作人员构成受贿罪，关系密切的人构成受贿罪的共犯，请托人构成行贿罪。

（2）如关系密切的人与国家工作人员没有通谋，亦即国家工作人员并不知情收受财物一事，只是承诺为请托人谋取不正当利益，对于收受财物一事与关系密切的人没有意思联络。则国家工作人员构成滥用职权类犯罪，关系密切的人构成利用影响力受贿罪，请托人构成对有影响力的人行贿罪。

【经典考题】

2023/客A/卷一/仿18. 关于贿赂犯罪，下列选项说法正确的是？[2]

A. 张某是律师，请A区法院院长李某帮忙介绍案源，李某遂让B区法院院长陈某给张某介绍了案源，后张某送给陈某好处费10万元，也送给李某好处费10万元。则李某不构成斡旋型受贿罪

B. 甲找到国家工作人员乙（乙同时也是某央企负责人国家工作人员丙的好友），让其帮忙找丙办事，乙收受甲的50万元之后，给丙打招呼把事办成了。则乙同时构成斡旋型受贿罪和利用影响力受贿罪

C. 甲想找市长丙帮忙，遂给丙的儿子乙送礼20万；乙将甲的请托事项告诉丙，丙起初不知道乙收了甲的钱，办完事情之后才知道收钱的事，但没有退还钱款。则乙构成利用影响力受贿罪，丙不构成犯罪

D. 甲为了找国家工作人员丙办事，先找到与丙关系很好的亲戚乙，让乙给丙打招呼；乙

[1] “罗菲受贿罪——如何认定特定关系人是否成立受贿罪共犯”，载最高人民法院刑事审判第一、二、三、四、五庭主编：《刑事审判参考》总第106辑，法律出版社2017年版，第47页。

[2] D

方鹏刑法讲义

收受甲的10万元之后，将甲的请托事项告知丙，丙却不同意帮忙。因事没有办成，乙遂将钱退还给甲。则乙构成利用影响力受贿罪既遂

2. **离职的国家工作人员**：利用影响力受贿罪与受贿罪（在职时谋利、离职后收钱）区别。在职时谋利、约定收钱为受贿罪，离职后谋利为利用影响力受贿罪。

离职的国家工作人员	在职时谋利	在职时约定收财	离职后收财	**受贿罪**
	离职后谋不当利	利用原职权		**利用影响力受贿罪**
	不能查明在职时有约定或未利用原职权			**不能认定犯罪**

离职的国家工作人员，收受请托人财物，为请托人谋取不正当利益。

（1）如离职的国家工作人员，是在职时为请托人谋取利益（正当、不正当皆可），并约定好离职后收受财物。则离职的国家工作人员构成受贿罪，请托人构成行贿罪。

（2）如离职的国家工作人员，是离职后才为请托人谋取不正当利益，并在离职后收受财物。则离职的国家工作人员构成利用影响力受贿罪，请托人构成对有影响力的人行贿罪。

3. **中间人**：利用官位影响，还是人身影响？是否有通谋？

中间人	利用“官位影响”+收钱+不正当利益	1. **斡旋型受贿罪**
	与受贿人通谋，帮受贿人收钱（行为人不一定要收钱）+利益	2. 受贿罪共犯
	利用“人身关系影响”+收钱+不正当利益	3. **利用影响力受贿罪**
	与行贿人通谋，帮行贿人送钱（行为人不一定要收钱）+行贿人为谋取不正当利益	4. 行贿罪共犯
	居中提供信息（行为人不一定要收钱）	5. **介绍贿赂罪**

【考点归纳】

★1. **利用影响力受贿罪与受贿罪共犯**：有通谋为受贿罪共犯，无通谋为利用影响力受贿罪。

2. **中间人**：

（1）利用**“官位”影响**+收钱+不当利益=**斡旋受贿**。

（2）与受贿人**通谋**（收不收钱均可），是**受贿罪共犯**。

（3）利用**人身影响**+收钱+不当利益=**影响力受贿**。

（4）帮行贿人送钱（收不收钱均可），是**行贿罪共犯**

（5）居中介绍（收不收钱均可），是**介绍贿赂**。

★3. “连环贿赂”倒着推，先看最终办事人。请托人甲送乙官钱，乙官送丙官钱。收钱+身份=受贿犯罪，送钱+对向人=行贿犯罪。

【经典考题】

【2024/客A/卷一/仿24：连环贿赂】某县规定，只有缴纳规定数额的税款才能获得购房资格。甲因为税款没缴够，没有购房资格。为了获得购房资格，请乙（非国家工作人员）帮忙；乙又找到了税务局的非国家工作人员的丙，许诺给其好处；丙因为自己不办理此业务，就又找到了同单位该税务局的国家工作人员丁，丁答应帮忙。后乙欺骗甲说需要钱去打点关系，还谎称要帮甲补缴税款，甲遂给了乙50万；接着乙拿出其中30万元给了丙，告诉丙说：“甲只给了我30万元，我都给你了。”丙自己留下20万元，给了丁10万元。丁误以为甲只给了其10

方鹏刑法讲义

万元，遂收下，在系统里伪造了甲的纳税记录。关于本案，下列说法正确的是？〔1〕

A. 甲构成行贿罪，犯罪数额为50万元

B. 乙构成诈骗罪，犯罪数额为20万元

C. 丙构成利用影响力受贿罪，犯罪数额为30万元

D. 丁构成受贿罪，犯罪数额为10万元

【拓展习题】

关于贿赂犯罪，下列哪些选项是错误的？〔2〕

A. 某省建设厅厅长A之妻甲（不具国家工作人员身份），在A完全不知情的情况下，向开发商索要10万元现金，称可以帮其批地，后甲找到该省所辖某县的建设局局长，声明自己厅长夫人的身份，果然事成，则甲构成受贿罪

B. 某县水务局科长甲不符合晋职条件仍想晋职，于是送给该水务局局长乙6万元，请托乙给该县组织部部长丙打招呼，果然事成，甲另行送给丙3万元。则乙构成介绍贿赂罪

C. 某公立医院医生甲收受某药厂药商乙3万元，故意在给病患开药方时多开该药厂的药品，则甲可构成受贿罪

D. 丁某原系某市市委书记，在任期间多次将大型公益广告项目批给广告商Y，Y多次表示要“感谢”，丁都回答说“退休后再说吧”，在丁退休后，Y给了丁200万元作为“感谢”，丁收下，则丁构成利用影响力受贿罪

★三、行贿罪

【相关法条】

第389条【行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的，是行贿罪。

在经济往来中，违反国家规定，给予国家工作人员以财物，数额较大的，或者违反国家规定，给予国家工作人员以各种名义的回扣、手续费的，以行贿论处。

【违法阻却事由】因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。

《刑法修正案（十二）》修正：第390条【对犯行贿罪的处罚规定】对犯行贿罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；因行贿谋取不正当利益，情节严重的，或者使国家利益遭受重大损失的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，或者使国家利益遭受特别重大损失的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

有下列情形之一的，从重处罚：

（一）多次行贿或者向多人行贿的；

（二）国家工作人员行贿的；

（三）在国家重点工程、重大项目中行贿的；

（四）为谋取职务、职级晋升、调整行贿的；

（五）对监察、行政执法、司法工作人员行贿的；

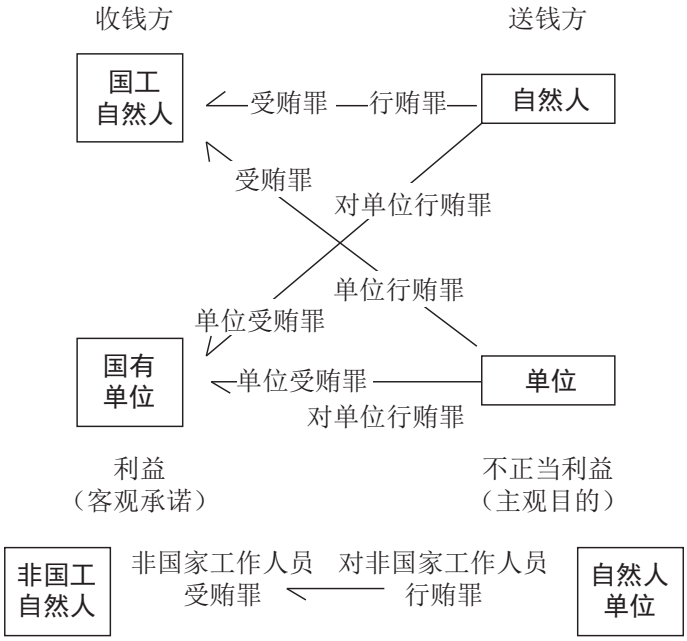
（六）在生态环境、财政金融、安全生产、食品药品、防灾救灾、社会保障、教育、医疗等领域行贿，实施违法犯罪活动的；

（七）将违法所得用于行贿的。

行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，对调查突破、侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

〔1〕 BCD 〔2〕 ABCD

【考点精析】



行贿罪，是指为谋取不正当利益，给予国家工作人员以财物的行为。

1. 主体及对象。行贿罪的主体是自然人，如果主体是单位，构成单位行贿罪。主体是国家工作人员（自然人），如对象为国有单位，构成对单位行贿罪。

2. **“为谋取不正当利益”（主观目的要素：想）。**

（1）“不正当利益”的内容：

①内容违法。指行贿者谋取的利益违反法律、法规、规章、政策规定。

②程序违法。指行贿者要求国家工作人员违反法律、法规、规章、政策、行业规范的规定，为自己提供帮助或者方便条件。

③不当竞争。违背公平、公正原则，在经济、组织人事管理等活动中，谋取竞争优势的，应当认定为“谋取不正当利益”。

（2）“谋取不正当利益”的定位：主观目的要素，即行贿者欲图谋取不正当利益，而并不一定要求实际上谋取到了不正当利益。在行贿者谋取到不正当利益之后，再主动给予国家工作人员财物，作为职务行为的报酬的，也认为具有“谋取不正当利益”的意图。

（3）行为人为了谋取正当利益，给予国家工作人员财物的，不构成行贿罪。但国家工作人员构成受贿罪。

【经典考题】

2005/2/65. 下列行为人所谋取的利益，哪些是行贿罪中的“不正当利益”？〔1〕

A. 甲向某国有公司负责人米某送3万元，希望能承包该公司正在发包的一项建筑工程

B. 乙向某高校招生人员刘某送3万元，希望刘某在招生时对其已经进入该高校投档线的女儿优先录取

C. 丙向某法院国家赔偿委员会委员高某送3万元，希望高某按照国家赔偿法的规定处理自己的赔偿申请

D. 丁向某医院药剂科科长程某送3万元，希望程某在质量、价格相同的条件下优先采购

〔1〕 ABD

丁所在单位生产的药品

3. **违法阻却事由：因被勒索给予国家工作人员以财物，没有获得不正当利益的，不是行贿。**

对此应当完整的解释为：（1）想谋不当利益：行为人主观上为了谋取不正当利益，被动给予国家工作人员财物；（2）被索贿：国家工作人员主动向行为人勒索财物；（3）实际没获不当利益：但事实上、客观上行为人没有谋取到不正当利益，送钱人不构成行贿罪，但索贿的国家工作人员构成受贿罪。

<table>
<tr><th colspan="4">行贿者</th><th>受贿者</th></tr>
<tr><td rowspan="4">为了谋取不正当利益</td><td rowspan="2">主动给予</td><td>已获得不正当利益</td><td rowspan="3">行贿罪</td><td rowspan="5">国家工作人员：受贿罪</td></tr>
<tr><td>未获得不正当利益</td></tr>
<tr><td rowspan="2">因勒索被动给予</td><td>已获得不正当利益</td></tr>
<tr><td>未获得不正当利益</td><td rowspan="2">无罪</td></tr>
<tr><td>为了谋取正当利益</td><td>主动给、被动给</td><td>已获得、未获得正当利益</td></tr>
</table>

4. **量刑从宽事由：追诉前主动交待，可以从轻、减轻、免除。**

<table>
<tr><th colspan="3">行贿人在被追诉前主动交待行贿行为</th><th>自首</th></tr>
<tr><td colspan="3">一般</td><td>可以从轻或减轻</td></tr>
<tr><td>犯罪较轻</td><td>对侦破重大案件起关键作用</td><td>有重大立功表现</td><td>可以减轻或免除</td></tr>
</table>

（1）行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，不属立功，属于自首。

①属于自首，不属立功。这是因为：行贿人揭发受贿者，是揭发对合犯（同案犯）共同犯罪事实，不构成立功，只能认为是《刑法》第67条自首。并且，因分则规定较总则规定处罚更轻，应按分则规定处罚。

②在处罚情形上：一般情形，可以从轻或者减轻。三种重大情形，包括犯罪较轻的，对侦破重大案件起关键作用的，或者有重大立功表现的，可以减轻或者免除处罚。

（2）行贿人揭发受贿人与其行贿无关的其他犯罪行为，查证属实的，依照《刑法》第68条关于立功的规定，可以从轻、减轻处罚。

（3）行贿人被追诉之后才如实供述自己罪行的，依照《刑法》第67条第3款（坦白）的规定，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

5. 罪数。行贿人谋取不正当利益的行为构成其他犯罪的，应当与行贿犯罪实行数罪并罚。

【考点归纳】

★1. **为了“不当利益”**（主观目的）有三种：内容违法、程序违法、不当竞争。

2. （1）想谋**正当利益**+送钱=无罪。（2）想谋不当利益+被勒索+没有实际获取=无罪。（3）想谋不当利益+主动送+有没有实际获取=行贿罪。

3. **追诉前交待**，一般只从、减；重大才减免。

4. 客观上对有影响力的人行贿行为+主观上对国工行贿故意=对有影响力的人行贿罪。

【拓展习题】

关于行贿犯罪，以下说法正确的有？〔1〕

A. 某交通局科员甲为了在组织人事管理中谋取竞争优势，主动送给该局党委书记乙10万元，希望乙在人事提拔中能够优先考虑其；乙虽答应，但并未在之后的人事任用中提拔甲。则甲不能构成行贿罪

B. 甲为违规获得黄金地块，而向市长乙送钱100万；因乙只拿钱不办事，甲遂向检察机关检举乙的受贿罪，为此而使乙的受贿罪受到追诉。则甲构成行贿罪，应当免除处罚

C. 请托人甲为了谋取不正当利益，到国家工作人员乙家中做客时，偷偷将一张价值6万元的购物卡放在乙家沙发垫下，当时并未告诉乙；后甲多次向乙暗示，乙都不知情；一个月后有人举报乙受贿事，纪检机关调查此事，乙才检查沙发发现购物卡。则甲可构成行贿罪，但乙不构成受贿罪

D. 甲因被某民营公司总经理乙勒索，而为了谋取不正当利益，送给乙一辆汽车，但甲并未获取到不正当利益，则甲不能构成对非国家工作人员行贿罪

四、介绍贿赂罪

第392条【介绍贿赂罪】向国家工作人员介绍贿赂，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

【追诉前交待可以减免】介绍贿赂人在被追诉前主动交待介绍贿赂行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。

五、单位受贿罪

《刑法修正案（十二）》修正：第387条第1款【单位受贿罪】国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体，索取、非法收受他人财物，为他人谋取利益，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

六、对单位行贿罪

《刑法修正案（十二）》修正：第391条【对单位行贿罪】为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

七、单位行贿罪

《刑法修正案（十二）》修正：第393条【单位行贿罪】单位为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节特别严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。因行贿取得的违法所得归个人所有的，依照本法第三百八十九条、第三百九十条的规定定罪处罚。

〔1〕 CD

方鹏刑法讲义

第四节　兜底型罪名

巨额财产来源不明罪

【相关法条】

第395条第1款【巨额财产来源不明罪】国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大的，可以责令该国家工作人员说明来源，不能说明来源的，差额部分以非法所得论，处五年以下有期徒刑或者拘役；差额特别巨大的，处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。

【考点精析】

巨额财产来源不明罪，是指国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入，差额巨大，不能说明来源的行为。在立法原理上，本罪是贪污罪、受贿罪的补充法，亦即在能够查明财产来源于贪污、受贿所得时，以贪污罪、受贿罪论处，在不能查明巨额财产的来源时，以本罪论处。

主体身份	国家工作人员
事实前提	财产、支出明显超过合法收入，差额巨大（以家庭计超30万）；可责令其说明来源
行为	不作为：不能说明来源（合法）
推定结论	差额部分以非法所得论

1. **主体身份（身份犯）：国家工作人员。**

2. 构成本罪的事实前提：国家工作人员的家庭财产、支出**明显超过合法收入，差额巨大**（差额在30万元以上）。

差额即“非法所得”的计算方法，一般是指行为人的家庭财产全部财产与能够认定的所有支出的总和减去能够证实的有真实来源的所得。在具体计算时，应注意以下问题：（1）以家庭财产为计算基础。应把国家工作人员个人财产和与其共同生活的家庭成员的财产、支出等一并计算，而且一并减去他们所有的合法收入以及确属与其共同生活的家庭成员个人的非法收入。（2）行为人所有的财产包括房产、家具、生活用品、学习用品及股票、债券、存款等动产和不动产；行为人的支出包括合法支出和不合法的支出，包括日常生活、工作、学习费用、罚款及向他人行贿的财物等；行为人的合法收入包括工资、奖金、稿酬、继承等法律和政策允许的各种收入。（3）为了便于计算犯罪数额，对于行为人的财产和合法收入，一般可以从行为人有比较确定的收入和财产时开始计算。

3. 行为人**不能说明来源**：指不能说明其来源合法，即推定为非法所得。在立法原理上是举证责任倒置，但在刑法层面上应当理解为不作为犯（对差额财产有说明来源合法的义务而不能说明）。

包括以下情况：（1）行为人拒不说明财产来源；（2）行为人无法说明财产的具体来源；（3）行为人所说的财产来源经司法机关查证并不属实；（4）行为人所说的财产来源因线索不具体等原因，司法机关无法查实，但能排除存在来源合法的可能性和合理性的。

4. 家庭财产差额巨大，夫妻双方均为国家工作人员的：只要夫妻双方都拥有超出合法收入的巨额财产（家庭财产超过合法收入60万元以上），有关机关可责令双方说明来源，夫妻双方均不能说明财产来源，二人均应认定为本罪。

微博“刑法学人方鹏”：学好真刑法，仗剑走天涯

5. 判决生效后发现新案情的处理。

（1）巨额财产来源不明罪判决生效，后发现不明财产来源于其他较重犯罪（如系贪污、受贿、盗窃、走私犯罪所得）的，除非启动审判监督程序，一般不再改判。

（2）巨额财产来源不明罪判决生效，后发现不明财产来源合法（如系炒股、做生意所得），或者来源于一般违法（如卖淫、制假所得）的，应以发现新证据为由（《刑诉法》253条第1项），改判无罪。

【经典考题】

2012/2/63. 国家工作人员甲与民办小学教师乙是夫妻。甲、乙支出明显超过合法收入，差额达300万元。甲、乙拒绝说明财产来源。一审中，甲交待300万元系受贿所得，经查证属实。关于本案，下列哪些选项是正确的？〔1〕

A. 甲构成受贿罪

B. 甲不构成巨额财产来源不明罪

C. 乙不构成巨额财产来源不明罪

D. 乙构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪

〔1〕 ABC

★第九章　渎职罪

本罪概说中需要掌握的知识点主要有：（1）本章罪名的法条竞合关系及处理方法。（2）受贿后又实施渎职犯罪的罪数认定。（3）国家机关工作人员与对向犯罪人构成共同犯罪及罪数认定。

【考点精析】

渎职罪，是指国家机关工作人员在职务活动中滥用职权、玩忽职守，使国家与人民利益遭受重大损失，损害职务行为公正性的犯罪。

★1. 本章罪名的法条竞合关系及处理方法

在法条竞合方面，《刑法》第397条规定的滥用职权罪（故意犯）、玩忽职守罪（过失犯）为一般法，本章其他罪名均为该两罪的特别法。

（1）滥用职权罪、玩忽职守罪为一般法，其他罪名是特别法。

一般法	滥用职权罪（故意犯）	玩忽职守罪（过失犯）	国家机关工作人员
特别法	徇私枉法罪		司法工作人员（刑诉职责）
	帮助犯罪分子逃避处罚罪		有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员
	私放在押人员罪	失职致使在押人员脱逃罪	司法工作人员（看管职责）
	徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪		司法工作人员（减刑、假释、暂予监外执行职责）
	执行判决、裁定滥用职权罪	执行判决、裁定失职罪	司法工作人员（执行职责）
	徇私舞弊不移交刑事案件罪		**行政执法人员**
	不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪		负有解救职责的国家机关工作人员
	徇私舞弊不征、少征税款罪		税务机关工作人员
	放纵走私罪		海关工作人员
		国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪	国家机关工作人员
	故意泄露国家秘密罪	过失泄露国家秘密罪	一般主体（保密义务）
当国家机关工作人员实施时	贪污罪、挪用公款罪		国家工作人员
	刑讯逼供罪、暴力取证罪；虐待被监管人罪		司法工作人员； 监管机关的监管人员
	非法拘禁罪		（国家机关工作人员利用职权犯该罪，从重处罚）

（2）法条竞合的处理规则：特别法优于一般法

①国家机关工作人员实施滥用职权或者玩忽职守犯罪行为，触犯刑法分则第9章第398条

方鹏刑法讲义

至第 419 条规定（特别法）的，依照该规定（特别法）定罪处罚。

②国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，因不具备徇私舞弊等情形，不符合刑法分则第 9 章第 398 条至第 419 条的规定（特别法），但依法构成第 397 条规定（一般法）的犯罪的，以滥用职权罪或者玩忽职守罪定罪处罚。

【经典考题】

2012/2/21. 下列哪一行为应以玩忽职守罪论处？〔1〕

A. 法官执行判决时严重不负责任，因未履行法定执行职责，致当事人利益遭受重大损失

B. 检察官讯问犯罪嫌疑人甲，甲要求上厕所，因检察官违规打开械具后未跟随，致甲在厕所翻窗逃跑

C. 值班警察与女友电话聊天时接到杀人报警，又闲聊 10 分钟后才赶往现场，因延迟出警，致被害人被杀、歹徒逃走

D. 市政府基建负责人因听信朋友介绍，未经审查便与对方签订建楼合同，致被骗 300 万元

2. 渎职罪的主体身份：国家机关工作人员。

本章罪名，除故意泄露国家秘密罪、过失泄露国家秘密罪的主体系一般主体以外，渎职罪的主体均为国家机关工作人员。

国家机关中从事公务的人员	（1）国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关中从事公务的人员
	（2）参照公务员条例管理的党、政、机关人员
	（3）立法解释规定的 3 种人： ①依照法律、法规规定行使职权的组织中从事公务的人员； ②在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员； ③虽未列入国家机关人员编制，但在国家机关中行使职权的人员

国家机关工作人员，通常包括三类人员：

（1）在国家权力机关（各级人大及常委会）、行政机关（各级政府及职能部门）、司法机关（各级法院、各级检察院）、军事机关（各级军区）中从事公务的人员。

（2）参照公务员条例管理的党、政、机关人员，例如各级党委中从事公务的人员，也认为是国家机关工作人员。

（3）根据立法解释，①依照法律、法规规定行使职权的组织中从事公务的人员；②在受国家机关委托代表国家机关行使职权的组织中从事公务的人员；③虽未列入国家机关人员编制，但在国家机关中行使职权的人员，也属国家机关工作人员。

相关司法解释也对一些特定情形进行了提示性规定，例如，镇财政所中按国家机关在编干部管理的工作人员，合同制民警在依法执行公务期间，经人事部门任命但为工人编制的乡（镇）工商所所长，企业事业单位的公安机构在机构改革过程中尚未列入公安机关建制的工作人员在行使侦查职责时，海事局及其分支机构工作人员，都属于国家机关工作人员。

【经典考题】

2022/客/1/28 仿．甲、乙二人系某派出所辅警，在值班路上遇见一名流浪汉丙，口吐白沫躺在路边。甲、乙二人遂将丙送往附近救助站。因担心麻烦，未将丙送入救助站内，而是将其放在救助站门口即离开。流浪汉丙爬起来走了两步，即摔倒不省人事，几小时后，被人发现送

〔1〕 C

注医院救治，两天后死亡。事后证明，如及时对丙进行救助，丙不会死亡。则关于甲、乙二人的行为性质，下列说法正确的有？〔1〕

A. 因甲、乙二人不是正式警察，故二人不构成玩忽职守罪

B. 甲、乙二人虽不是正式警察，但二人仍可构成滥用职权罪

C. 甲、乙二人应认定为过失致人死亡罪

D. 甲、乙二人构成不作为犯

3. 渎职罪多个罪名法条中“徇私舞弊”的定位和含义。

本章有多个罪名法条中使用了“徇私舞弊”一词（其中《刑法》第399条徇私枉法罪中使用了“徇私”“徇情”）。关于其定位，除《刑法》第397条（滥用职权罪、玩忽职守罪）第2款、第408条之一（食品、药品监管渎职罪）将“徇私舞弊”规定为情节加重犯的情节以外，其他条文均将“徇私舞弊”（或“徇私”、“舞弊”；“徇私”、“徇情”）规定为罪名基本罪状的内容。亦即除《刑法》第397条第2款（滥用职权罪、玩忽职守罪）、第408条之一（食品监管渎职罪）以外，“徇私舞弊”都是犯罪的构成要件要素。

(1)“徇私”系主观的动机要素。

(2)“舞弊”系客观的行为要素。

将“徇私”“舞弊”结合起来的“徇私舞弊”一词，实际上是与故意滥用职权的含义差不多的。虽形式上为罪名的构成要件要素，但一般而言并不需要进行特别判断，只要行为人故意实施了具体的滥用职权行为，就可认为是“徇私舞弊”。但《刑法》第397条第2款、第408条之一加重情节除外。

4. 国家机关工作人员不亲自实施本章之罪的情况。

（1）指令。国家机关负责人员违法决定，或者指使、授意、强令其他国家机关工作人员违法履行职务或者不履行职务，构成刑法分则第九章规定的渎职犯罪的，应当依法追究刑事责任。

（2）集体研究。以“集体研究”形式实施的渎职犯罪，应当依照刑法分则第九章的规定追究国家机关负有责任的人员的刑事责任。对于具体执行人员，应当在综合认定其行为性质、是否提出反对意见、危害结果大小等情节的基础上决定是否追究刑事责任和应当判处的刑罚。

★5. 受贿后又实施渎职犯罪的罪数认定。

国家机关工作人员实施渎职犯罪并收受贿赂，同时构成受贿罪的，除刑法另有规定外（徇私枉法罪，民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定滥用职权罪），以渎职犯罪和受贿罪数罪并罚。

择一重罪处断（非常态）	国家机关工作人员收受贿赂，并实施徇私枉法罪，民事、行政枉法裁判罪，执行判决、裁定滥用职权罪三罪之一（记忆罪名的方法：联想通常有法院刑庭、民庭、行政庭、执行庭）
数罪并罚（常态）	国家机关工作人员收受贿赂，并实施除上述三罪之外的其他渎职犯罪

★6. 国家机关工作人员与对向犯罪人构成共同犯罪及罪数认定。

无共谋不构成共犯，构成职务之罪	国家机关工作人员实施渎职行为，放纵他人犯罪或者帮助他人逃避刑事处罚，构成犯罪的，依照渎职罪的规定定罪处罚
有共谋仅利用职务，可构成共犯，同时与职务之罪择一重处	国家机关工作人员与他人共谋，利用其职务行为帮助他人实施其他犯罪行为，同时构成渎职犯罪和共谋实施的其他犯罪共犯的，依照处罚较重的规定定罪处罚

〔1〕 D

微博“刑法学人方鹏”：学好真刑法，仗剑走天涯

方鹏刑法讲义

续表

有共谋，既利用职务，又不利用职务，数罪并罚	国家机关工作人员与他人共谋，既利用其职务行为帮助他人实施其他犯罪，又以非职务行为与他人共同实施该其他犯罪行为，同时构成渎职犯罪和其他犯罪的共犯的，依照数罪并罚的规定定罪处罚

【考点归纳】

★1. **滥用职权罪**（对行为故意）、**玩忽职守罪**（对结果过失）是一般法，其他罪是特别法。

★2. **受贿后渎职**，除了三罪（徇私枉法、民事行政枉法裁判、执行判决裁定滥用职权），择一重处；其余均数罪并罚。

3. 国家机关人员与对向人：（1）无通谋，只构成渎职罪；（2）有通谋，可触犯共同犯罪、渎职罪，想象竞合；（3）既通谋、又不利用职权，数罪并罚。

【拓展习题】

关于渎职犯罪的罪数，以下说法正确的有？〔1〕

A. 监狱狱警甲收受服刑犯人乙的贿赂，编造虚假的减刑材料提交给法院，申请为乙减刑。则甲构成徇私舞弊减刑罪、受贿罪，应当数罪并罚

B. 海关工作人员甲在查获好友乙走私大宗淫秽物品入境时，顾及朋友情谊，假装没有看见，让乙顺利通关。则甲构成走私淫秽物品罪的共犯

C. 税务局工作人员甲与纳税人乙共谋，由乙虚报纳税资料，甲根据虚假纳税资料为乙违法减征税款100万元。则甲触犯徇私舞弊少征税款罪、逃税罪的共犯，应当依照处罚较重的规定定罪处罚

D. 公安局局长甲与拐卖妇女犯罪分子乙事先通谋，对于被乙拐卖的妇女不予以解救；某次甲接到被拐卖妇女亲属的解救要求，但拒不对被乙拐卖的妇女予以解救。此外，甲还曾为乙实施拐卖行为提供过交通工具。则甲触犯不解救被拐卖的妇女罪、拐卖妇女罪的共犯，应当数罪并罚

★一、滥用职权罪（故意）；玩忽职守罪（过失）

【相关法条】

第397条【滥用职权罪；玩忽职守罪】国家机关工作人员滥用职权或者玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

国家机关工作人员徇私舞弊，犯前款罪的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。本法另有规定的，依照规定。

【考点精析】

滥用职权罪，是指国家机关工作人员滥用职权，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。玩忽职守罪，是指国家机关工作人员玩忽职守，致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的行为。滥用职权罪、玩忽职守罪两罪的区别在于：滥用职权罪是故意犯，玩忽职守罪是过失犯。

〔1〕 ACD

方鹏刑法讲义

罪名	滥用职权罪（故意犯）	玩忽职守罪（过失犯）
主体身份	国家机关工作人员	
行为	违背职权、职责的行为。既可以是作为，也可以是不作为（不能以此来区分二者）	
结果（情节）	重大损失（职责范围内的损失，或背职行为导致的损失）	
罪过形式	（对行为）故意	（对结果）过失
加重犯	徇私舞弊的	
追诉时效	以结果发生时（犯罪成立时）起算	

1. **两罪的主体身份（身份犯）：国家机关工作人员。**

2. **两罪的行为：滥用职权行为、玩忽职守行为。**

（1）滥用职权行为，指故意违法行使职务的行为。包括：①超越职权，擅自决定或处理没有具体决定、处理权限的事项；②玩弄职权，随心所欲地对事项做出决定或者处理；③故意不履行应当履行的职责，任意放弃职责；④以权谋私、假公济私，不正确地履行职责。

（2）玩忽职守行为，指过失的不履行或者不认真履行职责的行为。包括：①疏忽不履行，即行为人应当履行且有条件、有能力履行职责，但因疏忽等原因违背职责没有履行，如擅离职守等；②不正确履行，即在履行职责的过程中，马虎草率、粗心大意，违反职责规定。

滥用职权行为、玩忽职守行为既可以是作为，也可以是不作为，不能以作为与不作为来区分二者，二者的关键区分在于故意和过失。滥用职权行为也可以是不作为，例如，故意不履行职责的行为，是不作为，系滥用职权行为；而玩忽职守行为也可以是作为，例如，马虎草率不正确履行职责的行为，是作为，系玩忽职守行为。

3. **两罪均以“重大损失”为必要构成要素**：致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失。

（1）滥用职权罪、玩忽职守罪的“重大损失”要求是一样的。一般要求造成死亡 1 人以上，或者重伤 3 人以上，或者轻伤 9 人以上，或者重伤 2 人、轻伤 3 人以上，或者重伤 1 人、轻伤 6 人以上的；造成经济损失 30 万元以上的；造成恶劣社会影响的；其他致使公共财产、国家和人民利益遭受重大损失的情形。

（2）“重大损失”在二罪中的体系地位不一样。在滥用职权罪相当于“情节严重”的情节要素（无需故意认识），而在玩忽职守罪中属于真正的结果要素。

4. 要求“重大损失”与滥用职权行为、玩忽职守行为之间具有因果关系。是因其职责范围内的行为而引起，与其职务行为有关。

5. **两罪的罪过形式：故意（滥用职权罪）VS 过失（玩忽职守罪）。**

（1）滥用职权罪的罪过形式是故意。这里的故意，指对滥用职权行为的故意，亦即明知行为违背职责仍故意实施，即有滥用职权罪的故意。注意：滥用职权罪的故意不是对损害结果的故意。滥用职权罪中的“重大损失”，实为“情节严重”的情节要素，是“客观的超过要素”（罪量要素），无需行为人对此结果明知、希望与放任，只需有认识可能性，即能成立本罪的故意。

（2）玩忽职守罪的罪过形式是过失。即出于疏忽、马虎草率、粗心大意，应当履行或正确履行职责而未履行，从而导致结果。有时也表现为监督过失，即行为人应当监督直接责任者却没有实施监督行为，导致了结果发生。意外事件，即使认真履行职责也不能避免，不能构成本罪。

方鹏刑法讲义

（3）滥用职权罪与玩忽职守罪两罪之间的重要区别即在于罪过形式，滥用职权罪是故意犯罪，玩忽职守罪是过失犯罪。由此，当国家机关工作人员在因不当履行职责中而造成重大损害时，先看其是否故意实施违背职责的行为，如果故意违背职责，则构成滥用职权罪。如果非故意违背职责，则看其对结果是否具有过失，如系过失实施的违背职责的行为，则构成玩忽职守罪。如属意外事件，则不能追究。

6. 徇私舞弊的，系前两罪的加重犯。

7. 追诉时效起算点：结果发生时。

滥用职权、玩忽职守行为造成的重大损失当时没有发生，而是滥用职权、玩忽职守行为之后一定时间发生的，应从危害结果发生之日起计算滥用职权罪、玩忽职守罪的追诉期限。

【经典考题】

2016/2/63. 关于渎职犯罪，下列哪些选项是正确的？〔1〕

A. 县财政局副局长秦某工作时擅离办公室，其他办公室人员操作电炉不当，触电身亡并引发大火将办公楼烧毁。秦某触犯玩忽职守罪

B. 县卫计局执法监督大队队长武某，未能发现何某在足疗店内非法开诊所行医，该诊所开张三天即造成一患者死亡。武某触犯玩忽职守罪

C. 负责建房审批工作的干部柳某，徇情为拆迁范围内违规修建的房屋补办了建设许可证，房主凭此获得补偿款 90 万元。柳某触犯滥用职权罪

D. 县长郑某擅自允许未经环境评估的水电工程开工，导致该县水域内濒危野生鱼类全部灭绝。郑某触犯滥用职权罪

二、司法工作人员渎职犯罪

过程	罪名	典型事例	关联罪名
刑事诉讼	**徇私枉法罪（司法工作人员）**	刑事诉讼中的刑警、检察官、刑庭法官故意乱办案	滥用职权罪
抓捕	帮助犯罪分子逃避处罚罪（查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员）	警察给通缉犯报信	窝藏、包庇罪
看押	私放在押人员罪（故意） 失职致使在押人员脱逃罪（过失）	押解、看守所、监狱的警察、检察官让在押犯逃走	脱逃罪
行刑	**徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪（司法工作人员）**	狱警、法官故意乱报材料、裁定减刑、假释、监外执行	伪证罪
民行诉讼	民事、行政枉法裁判罪	民事、行政诉讼中的法官故意乱办案	滥用职权罪
执行	执行判决、裁定滥用职权罪（故意） 执行判决、裁定失职罪（过失）	执行庭法官乱执行	拒不执行判决、裁定罪
行政	**徇私舞弊不移交刑事案件罪**	**行政执法人员不移送**	

〔1〕 CD

方鹏刑法讲义

★（一）徇私枉法罪

【《中国审判案例要览（2002年刑事审判案例卷）》：安军文等徇私枉法案〔1〕】被告人安军文等五人，均为北京铁路局太原铁路公安处乘警支队民警。在担任旅客列车乘警期间，在明知列车发生旅客财物被盗案件的情况下，3次收受盗窃分子丁玉良等人送给的盗窃所得赃款6000余元，不履行公安人员的侦查职责，对丁玉良等人予以包庇，将犯罪嫌疑人放走，瞒案未上报。

【问题】安军文等人的行为如何定性？

【相关法条】

第399条第1款【徇私枉法罪】司法工作人员徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉、对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。

【考点精析】

徇私枉法罪，是指司法工作人员在刑事诉讼中徇私枉法、徇情枉法，对明知是无罪的人而使他受追诉，对明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉，或者在刑事审判活动中故意违背事实和法律作枉法裁判的行为。即刑事诉讼中的侦、检、审人员故意乱判案。本罪的法益为刑事追诉活动的正当性以及公民的自由与权利。

1. **构成特征。**

主体身份（身份犯）：刑事司法工作人员	刑事诉讼中负有侦查、检察、审判、监管职责的司法工作人员。如刑警、检察官、法院刑庭审判人员、监狱侦查人员
时空环境：在刑事诉讼活动中，包括刑事附带民事诉讼之中	民事诉讼、行政诉讼中的司法工作人员故意乱判案，构成民事、行政枉法裁判罪
枉法行为：违背事实和法律对刑事案件作枉法裁判	故意地有罪判无、无罪判有；重罪轻判、轻罪重判；其他乱判
罪过形式：故意，出于徇私、徇情动机	因法律水平不高、事实掌握不全而过失造成错判，不构成本罪；确有重大过失造成重大损失结果的，可触犯玩忽职守罪

（1）主体身份（身份犯）：刑事司法工作人员。指在刑事诉讼中负有侦查、检察、审判、监管职责的司法工作人员。常见的情形如刑警、检察官、法院刑庭审判人员、监狱侦查人员。

（2）时空环境：在刑事诉讼活动中，包括刑事附带民事诉讼之中。民事诉讼、行政诉讼中的司法工作人员故意乱判案，构成民事、行政枉法裁判罪。

（3）徇私枉法行为：违背事实和法律对刑事案件作枉法裁判。

①对明知是无罪的人而使他受追诉。即对明知是无罪的人，采取伪造、隐匿、毁灭证据或者其他隐瞒事实、违反法律的手段，实行立案、侦查、起诉、审判、作为“逃犯”在网上通缉等。

②明知是有罪的人而故意包庇不使他受追诉。即对明知是有犯罪事实需要进行追诉的人：a. 采取伪造、隐匿、毁灭证据、故意不收集有罪证据，或者其他隐瞒事实、违反法律的手段，故意包庇使其不受立案、侦查、起诉、审判。b. 或者在立案后，采取伪造、隐匿、毁灭证据

〔1〕国家法官学院、中国人民大学法学院编：《中国审判案例要览（2002年刑事审判案例卷）》，中国人民大学出版社2003年版。

方鹏刑法讲义

或者其他隐瞒事实、违反法律的手段，应当采取强制措施而不采取强制措施。c. 或者虽然采取强制措施，但中断侦查或者超过法定期限不采取任何措施，实际放任不管，以及违法撤销、变更强制措施，致使犯罪嫌疑人、被告人实际脱离司法机关侦控。

③在刑事审判活动中故意违背事实和法律，作出枉法判决、裁定。包括无罪判有罪、有罪判无罪，重罪轻判、轻罪重判；以及科刑时明显加重、减轻处罚；或者改变判决、裁定、决定理由，使法律后果实质上有重大不同。

（4）罪过形式：故意，出于徇私、徇情动机。因法律水平不高、事实掌握不全而过失造成错判，不构成本罪；确有重大过失造成重大损失结果的，可触犯玩忽职守罪。

2. 此罪彼罪：徇私枉法罪与包庇罪，帮助毁灭、伪造证据罪，妨害作证罪，伪证罪的关系和区分。

（1）司法工作人员利用本人具体承办该案件的职务便利包庇犯罪人，帮助毁灭、伪造证据，妨害证人作证，作伪证的，可触犯妨害司法类犯罪与徇私枉法罪，是部分法与整体法的法条竞合关系，应以整体法徇私枉法罪论罪。

（2）一般公民，或者没有具体承办该案件的司法工作人员，包庇犯罪人，帮助毁灭、伪造证据，妨害证人作证，作伪证的，构成包庇罪，帮助毁灭、伪造证据罪，妨害作证罪，伪证罪。

3. 罪数：受贿后徇私枉法，择一重罪处断。

司法工作人员贪赃枉法，有徇私枉法行为而又有受贿行为的，依处罚较重的规定定罪处罚。

【经典考题】

2009/2/65. 关于徇私枉法罪，下列哪些选项是正确的？〔1〕

A. 甲（警察）与犯罪嫌疑人陈某曾是好友，在对陈某采取监视居住期间，故意对其放任不管，导致陈某逃匿，司法机关无法对其追诉。甲成立徇私枉法罪

B. 乙（法官）为报复被告人赵某对自己的出言不逊，故意在刑事附带民事判决中加大赵某对被害人的赔偿数额，致使赵某多付10万元。乙不成立徇私枉法罪

C. 丙（鉴定人）在收取犯罪嫌疑人盛某的钱财后，将被害人的伤情由重伤改为轻伤，导致盛某轻判。丙不成立徇私枉法罪

D. 丁（检察官）为打击被告人程某，将对程某不起诉的理由从“证据不足，指控犯罪不能成立”擅自改为“可以免除刑罚”。丁成立徇私枉法罪

【拓展习题】

关于渎职犯罪，以下说法正确的有？〔2〕

A. 刑警甲为了报复A某，利用侦办某起杀人案件的便利，将A某的衣物、鞋置放于犯罪现场，并以此为由将A某列为犯罪嫌疑人予以侦查拘留。甲构成滥用职权罪

B. 某派出所民警乙负责对取保候审的B某进行监管，但乙故意对其放任不管，导致B某逃走。乙构成私放在押人员罪

C. 税务机关工作人员丙收取C的钱财2万元后，违法为不符合免税条件的C办理免税手续。丙构成徇私舞弊不征、少征税款罪与受贿罪，应数罪并罚

D. 某县公安局局长丁，在获知上级公安部门下达抓捕D的命令后，鉴于D是其好友，打电话通知D逃走。丁构成窝藏、包庇罪

---

〔1〕 ACD 〔2〕 C

方鹏刑法讲义

（二）执行判决、裁定滥用职权罪（故意）；执行判决、裁定失职罪（过失）

【相关法条】

第399条第3款【执行判决、裁定失职罪；执行判决、裁定滥用职权罪】（司法工作人员）在执行判决、裁定活动中，严重不负责任或者滥用职权，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；致使当事人或者其他人的利益遭受特别重大损失的，处五年以上十年以下有期徒刑。

【考点精析】

执行判决、裁定滥用职权罪，是指司法工作人员在执行判决、裁定活动中，滥用职权，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的行为。本罪为故意犯罪。执行判决、裁定失职罪，是指司法工作人员在执行判决、裁定活动中，严重不负责任，不依法采取诉讼保全措施、不履行法定执行职责，或者违法采取诉讼保全措施、强制执行措施，致使当事人或者其他人的利益遭受重大损失的行为。本罪为过失犯罪。

1. **主体身份（身份犯）：司法工作人员**，指负有执行判决、裁定职责的司法工作人员。常见的如法院执行庭的法官等。

2. “判决、裁定”：指法院作出的生效的判决、裁定。包括民事、行政方面的判决、裁定，诉讼保全措施；也包括部分刑事判决与裁定，如没收财产或罚金判决。但不能包括民事调解、仲裁文书等非审判行为的结论；当然，如果法院就民事调解、仲裁文书作出裁定，则也应认定为裁定。

3. 结果：此罪需遭受重大损失的实害结果，才能成立犯罪。

4. 罪过形式：（1）执行判决、裁定滥用职权罪，系故意。这里的故意，同样指对滥用执行判决、裁定职权行为具有故意，即明知行为违法仍然实施，而不是对损害结果的故意。（2）执行判决、裁定失职罪，系过失。

5. 罪数：受贿后又实施执行判决、裁定滥用职权罪的，择一重罪处断。

（三）私放在押人员罪（故意）；失职致使在押人员脱逃罪（过失）

【相关法条】

第400条【私放在押人员罪】司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑。

【失职致使在押人员脱逃罪】司法工作人员由于严重不负责任，致使在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯脱逃，造成严重后果的，处三年以下有期徒刑或者拘役；造成特别严重后果的，处三年以上十年以下有期徒刑。

【考点精析】

私放在押人员罪，是指司法工作人员私放在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯的行为。失职致使在押人员脱逃罪，是指司法工作人员由于严重不负责任，致使在押的犯罪嫌疑人、被告人或者罪犯脱逃，造成严重后果的行为。

1. **两罪的主体身份（身份犯）：司法工作人员**，指对犯罪嫌疑人、被告人或罪犯负有监管职责的司法工作人员。

主要是监狱警察、看守所公安人员等监管机关的监管人员；还包括被监管机关聘用、委托、委派承担监管职责的人员。例如被监管机关聘用受委托履行监管职责的工人等非监管机关在编监管人员；未被公安机关正式录用，但受委托履行监管职责的人员；以及受委派承担监管

职责的狱医等人员。

2. **两罪的对象：在押（包括在羁押场所和押解途中）的犯罪嫌疑人、被告人或罪犯。**

（1）犯罪嫌疑人、被告人或罪犯。私放被行政拘留、司法拘留以及劳动教养的人员的，不成立本罪，可涉嫌滥用职权罪等。

（2）系在押人员。对未被关押的犯罪嫌疑人、被告人或罪犯放任不管，令其脱离控制，不成立本罪，可涉嫌徇私枉法罪、滥用职权罪等。

3. 两罪的行为：私放行为，使其脱逃。

私放行为，即非法释放在押人员。包括作为、不作为。例如，伪造有关法律文书释放在押人员；明知罪犯脱逃而故意不阻拦、不追捕，等等。

4. 罪过形式：（1）私放在押人员罪，故意；（2）失职致使在押人员脱逃罪，过失。

5. **私放在押人员罪与徇私枉法罪的关系：**一定程度上是特别法与一般法的法条竞合关系。私放行为是一种更加特别的徇私枉法。监管人员利用监管职责私放在押人员的，同时触犯二罪的，应当以特别法私放在押人员罪论处。

6. 私放在押人员罪与脱逃罪的共犯。

（1）非司法工作人员帮助在押人员脱逃的，构成脱逃罪的共犯。

（2）司法工作人员没有利用职务上的便利，而帮助在押人员脱逃，构成脱逃罪的共犯。

（3）司法工作人员主动私放在押人员时，司法工作人员构成私放在押人员罪，被释放的在押人员不成立脱逃罪，也不成立私放在押人员罪的共犯。

（4）在押人员脱逃时，司法工作人员故意不制止、不追捕；或者在押人员与司法工作人员相勾结，使在押人员脱逃。在押人员成立脱逃罪，司法工作人员同时触犯私放在押人员罪与脱逃罪的共犯，系想象竞合，应当择一重罪处断。

【经典考题】

【2025/客A/卷一/仿34：徇私枉法罪、玩忽职守罪、滥用职权罪】某法院法官赵某因重大失误，导致无罪人员张某被错判6年有期徒刑。后查明，在审理案件过程中，赵某不存在徇私、徇情情节。关于赵某的行为性质，下列说法正确的有？[1]

A. 赵某不构成徇私枉法罪　　B. 赵某构成玩忽职守罪

C. 赵某构成非法拘禁罪　　D. 赵某不构成滥用职权罪

（四）徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪

【相关法条】

第401条【徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪】司法工作人员徇私舞弊，对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯，予以减刑、假释或者暂予监外执行的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

【考点精析】

徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪，指司法工作人员徇私舞弊，对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯予以减刑、假释、暂予监外执行的行为。大体上包括以下情形：

（1）刑罚执行机关的工作人员（如狱警、监管人员）对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯，捏造事实，伪造材料，违法报请减刑、假释、暂予监外执行的。

（2）审判人员对不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯，徇私舞弊，违法裁定减刑、假释或者违法决定暂予监外执行的。

（3）监狱管理机关、公安机关的工作人员对不符合暂予监外执行条件的罪犯，徇私舞弊，

---

[1] ABD

违法批准暂予监外执行的。

（4）不具有报请、裁定、决定或者批准减刑、假释、暂予监外执行权的司法工作人员利用职务上的便利，伪造有关材料，导致不符合减刑、假释、暂予监外执行条件的罪犯被减刑、假释、暂予监外执行的。

（5）其他徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行应予追诉的情形。

（五）帮助犯罪分子逃避处罚罪

【相关法条】

第417条【帮助犯罪分子逃避处罚罪】有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑。

【考点精析】

帮助犯罪分子逃避处罚罪，是指有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的行为。

1. 主体身份（身份犯）：负有查禁犯罪活动职责的国家机关工作人员，但并不要求对该犯罪具有刑事追诉权限。包括司法工作人员，也包括其他国家机关工作人员。本罪是职务犯罪，必须利用查禁犯罪活动职责实施犯罪。

2. 帮助犯罪分子逃避处罚的行为（最典型的情况是向犯罪分子通风报信、提供便利），包括：

（1）向犯罪分子泄漏有关部门查禁犯罪活动的部署、人员、措施、时间、地点等情况的。

（2）向犯罪分子提供钱物、交通工具、通信设备、隐藏处所等便利条件的。

（3）向犯罪分子泄漏案情的。

（4）帮助、示意犯罪分子隐匿、毁灭、伪造证据，或者串供、翻供的。

（5）其他帮助犯罪分子逃避处罚应予追诉的情形。

3. 帮助犯罪分子逃避处罚罪与徇私枉法罪的关系。一定程度上可以认为是特别法与一般法的法条竞合关系。帮助犯罪分子逃避处罚罪是更为特别的徇私枉法罪，以特别法论处。

4. **帮助犯罪分子逃避处罚罪与窝藏罪、包庇罪的区别**：是否利用具体查禁该案的职责。

国家机关工作人员利用职务向犯罪分子通风报信、提供便利，帮助犯罪分子逃避处罚的，构成帮助犯罪分子逃避处罚罪；如未利用职务、与其职责无关联，则构成窝藏罪、包庇罪。例如，甲在A地杀人未被侦破时，逃到B地的朋友乙家（乙系当地民警），乙出门打听消息、提供钱财，帮甲逃走。乙并未利用查禁犯罪的职责，故构成窝藏罪。

（六）徇私舞弊不移交刑事案件罪：行政执法人员不移交

第402条【徇私舞弊不移交刑事案件罪】**行政执法人员**徇私舞弊，对依法应当移交司法机关追究刑事责任的不移交，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；造成严重后果的，处三年以上七年以下有期徒刑。

【考点归纳】

★1. **徇私枉法罪**：发生在刑事诉讼中（广义的涉刑案司法程序），司法工作人员乱办案。

2. **私放在押人员罪**：对象是“在押”人员。取保候审、监视居住；管制、缓刑、假释、监外执行人员，不属“在押”人员；放走不在押人犯，可构成徇私枉法罪。

微博“刑法学人方鹏”：学好真刑法，仗剑走天涯

方鹏刑法讲义

★3. **徇私舞弊减刑、假释、暂予监外执行罪**，与减刑、假释、暂予监外执行制度结合。

4. 有查禁犯罪职责的国家机关工作人员，给罪犯通风报信，构成**帮助犯罪分子逃避处罚罪**。没有职责或没有利用职责，构成**窝藏、包庇罪**。

【拓展习题】

关于司法人员相关犯罪，以下说法不正确的有？〔1〕

A. 乙因合同诈骗罪被判处有期徒刑，在监狱服刑期间因患病而被送入监狱医院住院治疗，监狱委托狱医甲负责对其进行监管。期间，乙提出回家的请求，甲出于对乙的同情，未经监狱机关批准私下准许乙回家三天，三天后乙如期回到监狱医院。因“脱逃”要求永久脱离监管，则甲不能构成私放在押人员罪，乙也不能构成脱逃罪

B. 刑警甲为侦破丙涉嫌强奸一案，而对被害人乙实施殴打，逼取被害人乙的陈述，导致乙自杀身亡。因被害人不是证人，故甲不能构成暴力取证罪

C. 法院执行庭的法官甲，在乙提交法院生效判决向其申请强制执行时，因其与乙有矛盾，明知其符合申请强制执行条件，而故意不予以受理，导致乙遭受特别重大损失，则甲构成拒不执行判决、裁定罪

D. 被告人乙（19周岁）与他人一起对被害人实施轮奸后，被公安机关拘留，为使乙得到轻判，乙的母亲丙请户籍警甲将乙的年龄改为17周岁，则甲构成徇私枉法罪

三、本章其他渎职犯罪

渎职犯罪	对合罪名及关联罪名
徇私舞弊不征、少征税款罪	逃税罪
放纵走私罪	走私犯罪
不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪	聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童罪；妨害公务罪
故意泄露国家秘密罪（故意） 过失泄露国家秘密罪（过失）	非法获取国家秘密罪

（一）徇私舞弊不征、少征税款罪：税务人员不征税

【相关法条】

第404条【徇私舞弊不征、少征税款罪】税务机关的工作人员徇私舞弊，不征或者少征应征税款，致使国家税收遭受重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑。

【考点精析】

徇私舞弊不征、少征税款罪，是指税务机关的工作人员徇私舞弊，不征或者少征应征税款，致使国家税收遭受重大损失的行为。

1. **主体身份（身份犯）：税务机关工作人员。**

2. 徇私舞弊不征、少征税款的行为：

（1）不征，是指违反税法规定，不向纳税人征收应征税款，即擅自免征。少征，是指违反

〔1〕 ABCD

方鹏刑法讲义

税法规定，降低税收额或征税率进行征收，即擅自减征。

（2）“国家税收”：应作广义理解，包括国家税收（国税），也包括地方税收（地税）。

3. 结果：致使国家税收遭受重大损失（10万元以上）。

4. 责任：故意，具有徇私动机。过失不征、少征税款，致使国家利益遭受重大损失的，以玩忽职守罪论处。

5. 徇私舞弊不征、少征税款罪与逃税罪的共同犯罪的关系。

（1）税务机关的工作人员，与逃税者无共谋构成徇私舞弊不征、少征税款罪。

（2）税务机关的工作人员，与逃税者有共谋，相互勾结，不征或者少征应征税款的，触犯徇私舞弊不征、少征税款罪与逃税罪的共犯，系想象竞合，应当择一重罪处断。

【经典考题】

2000/2/31. 税务稽查员甲发现A公司欠税80万元，便私下与A公司有关人员联系，要求对方汇10万元到自己存折上以了结此事。A公司将10万元汇到甲的存折上以后，甲利用职务上的便利为A公司免交80万元税款办理了手续应如何处理？（同时也是2002/2/10）〔1〕

A. 认定为徇私舞弊不征、少征税款罪，从重处罚

B. 认定为受贿罪，从重处罚

C. 认定为徇私舞弊不征、少征税款罪与受贿罪的竞合，从一重罪处罚

D. 认定为徇私舞弊不征、少征税款罪与受贿罪，实行并罚

（二）放纵走私罪：海关人员不查走私

【相关法条】

第411条【放纵走私罪】海关工作人员徇私舞弊，放纵走私，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。

【考点精析】

放纵走私罪，是指海关工作人员徇私舞弊，放纵走私，情节严重的行为。

1. **主体身份（身份犯）：海关工作人员。**

2. 放纵走私的行为：放任、纵容走私。包括：

（1）不征关税。故意放纵走私，不缉查走私货物、物品，不依法征收关税。

（2）不处罚走私人。故意放纵走私罪犯或一般走私违法者，不进行处理、抓捕。

放纵走私，指对正在进行的走私行为不制止。如果走私行为已经实施完毕，而对走私犯罪分子予以窝藏、包庇，构成徇私舞弊不移交刑事案件罪，窝藏、包庇罪，或者包庇毒品犯罪分子罪等。例如，《刑法》第349条第2款明确规定缉毒人员或者其他国家机关工作人员掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，依照包庇毒品犯罪分子罪的规定从重处罚。

3. 这里被放纵的“走私”，既包括《刑法》第三章第二节的走私犯罪（例如走私普通、货物物品罪，走私贵重金属罪，走私武器、弹药罪，走私淫秽物品罪等），也包括《刑法》第六章第七节第347条的走私毒品罪。海关工作人员放纵走私毒品的，也触犯放纵走私罪。缉毒人员或者其他国家机关工作人员在事后掩护、包庇走私、贩卖、运输、制造毒品的犯罪分子的，构成包庇毒品犯罪分子罪。

4. 放纵走私罪与走私罪共同犯罪的关系。

（1）海关工作人员，与走私者无共谋，放纵走私的，构成放纵走私罪。

（2）海关工作人员，与走私者有共谋，放纵走私的，触犯放纵走私罪、走私犯罪的共同犯罪，系想象竞合，应当择一重罪处断。

---

〔1〕 D

方鹏刑法讲义

（三）不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪：警察等不解救

【相关法条】

第416条第1款【不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪】对被拐卖、绑架的妇女、儿童负有解救职责的国家机关工作人员，接到被拐卖、绑架的妇女、儿童及其家属的解救要求或者接到其他人的举报，而对被拐卖、绑架的妇女、儿童不进行解救，造成严重后果的，处五年以下有期徒刑或者拘役。

【考点精析】

不解救被拐卖、绑架的妇女、儿童罪，是指对被拐卖、绑架的妇女、儿童负有解救职责的国家机关工作人员，接到被拐卖、绑架的妇女、儿童及其亲属的解救要求或者接到其他人的举报，而对被拐卖、绑架的妇女、儿童不进行解救，造成严重后果的行为。

1. 主体身份：负有解救职责的国家机关工作人员。

2. 不解救行为：纯正不作为。有解救职责、能够解救而不解救。

3. 对象：被拐卖、绑架的妇女、儿童。

（1）“被拐卖的妇女、儿童”，既包括被拐卖但还没有出卖的妇女、儿童，也包括拐卖过程中以及拐卖后被收买的妇女、儿童。本罪的对象与聚众阻碍解救被收买的妇女、儿童罪（《刑法》第242条第2款）的对象“被收买的妇女、儿童”（只包括被收买的妇女、儿童，不包括被拐卖但还没有出卖的妇女、儿童），有所不同。

（2）“被绑架的妇女、儿童”，专门指因拐卖妇女、儿童罪（《刑法》第240条）而被控制、绑架的妇女、儿童。亦即，是作为拐卖妇女、儿童罪对象的妇女、儿童，而不是指因绑架罪（《刑法》第239条）而被控制、绑架的妇女、儿童。

亦即负有解救职责的国家机关工作人员，不解救作为拐卖妇女、儿童罪对象的妇女、儿童，构成不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪；不解救作为绑架罪对象的妇女、儿童（以及男子），不构成不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪，而应构成滥用职权罪。

4. 结果：造成严重后果。

5. 本罪与拐卖类犯罪的关系。

（1）与拐卖者无共谋，不解救的，构成本罪。

（2）与拐卖者有共谋，不解救的，触犯不解救被拐卖、绑架妇女、儿童罪，拐卖犯罪的共同犯罪，系想象竞合，应当择一重罪处断。

四、故意泄露国家秘密罪（故意）；过失泄露国家秘密罪（过失）：保密人员乱说秘密

【相关法条】

第398条【故意泄露国家秘密罪；过失泄露国家秘密罪】国家机关工作人员违反保守国家秘密法的规定，故意或者过失泄露国家秘密，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑。

非国家机关工作人员犯前款罪的，依照前款的规定酌情处罚。

【考点精析】

故意泄露国家秘密罪，是指国家机关工作人员或其他有关人员，违反保守国家秘密法的规定，故意泄露国家秘密，情节严重的行为。过失泄露国家秘密罪，是指国家机关工作人员或其他有关人员，违反保守国家秘密法的规定，过失泄露国家秘密，情节严重的行为。

1. **本罪主体为一般主体。**包括合法掌握国家秘密的人（如国家秘密的合法知悉者），以及偶然掌握国家秘密的人（例如偶然听得），或者非法掌握国家秘密但负有保密义务的人（如窃取到含有国家秘密的财物的人），包括国家机关工作人员或其他有关人员。

方鹏刑法讲义

2. “泄露”：指违反保守国家秘密法的规定，使国家秘密被不应当知悉者知悉，或使国家秘密超出了限定的接触范围。泄露的方法包括提供阅读、准许复制、交谈、通信，在公共场所谈论国家秘密，提供属于国家秘密的设备或产品，在报刊上、网络上披露、张贴等。

3. 罪过形式：对泄露国家秘密是故意的，构成故意泄露国家秘密罪；是过失的，构成过失泄露国家秘密罪。

4. 与其他涉密犯罪的关系。

（1）合法掌握国家秘密的人，明知对方为境外机构、组织、人员，而向其泄露国家秘密的，构成为境外机构、组织、人员非法提供国家秘密罪；明知对方是间谍人员而为其提供国家秘密，使其泄露的，构成间谍罪。

（2）对于国家秘密没有合法掌握权的人，非法获取国家秘密之后，又故意泄露该国家秘密的，因涉及同一对象同一法益，宜从一重罪处断。

【经典考题】

2020/客/卷一/仿 42. 关于渎职罪的认定，下列选项说法正确的是？〔1〕

A. 国家机关以“集体研究”形式实施的渎职犯罪，负责人员可被追究刑事责任，具体执行人员也有可能被追究刑事责任

B. 税务局工作人员甲因为工作失误漏征税款，给国家造成重大税收损失，甲构成徇私舞弊不征、少征税款罪

C. 警察甲在接到被拐卖儿童家属的解救要求后，故意不解救被拐卖儿童，甲构成不解救被拐卖儿童罪、滥用职权罪，应当择一重处

D. 狱警甲明知被关押的罪犯乙可能逃脱，仍未采取相关措施阻止，导致乙逃脱。甲构成私放在押人员罪、脱逃罪的帮助犯，应当数罪并罚

【拓展习题】

以下关于滥用职权行为的情形说法正确的有？〔2〕

A. 国家机关工作人员甲，在收受被执行人贿赂后与之通谋，以权谋私，利用其职权帮助被执行人妨害法院生效判决、裁定的执行，致使判决、裁定无法执行的，触犯受贿罪，滥用职权罪（或执行判决、裁定滥用职权罪），拒不执行判决、裁定罪，择一重罪处断或数罪并罚（受贿罪并罚）

B. 交通局工作人员乙，明知是登记手续不符合规定的机动车，仍徇私舞弊办理登记手续，致使数十辆被盗机动车被办理登记手续，其行为构成盗窃罪的共犯

C. 国家机关工作人员丙管理石油开采工作，群众曾向其举报 C 某等人在该地未经依法批准擅自从事石油开采违法活动，丙前往调查，因受到 C 某丰盛的招待，有意不对其行为进行查封、取缔，导致当地石油资源遭到巨大损失，丙的行为构成滥用职权罪

D. 某县县委书记丁，在签订招商引资合同时，明知对方存在重大诈骗嫌疑，为了政绩未履行细致审查职责，仍然执意签订合同，导致该县损失 1 千万，则丁构成滥用职权罪

〔1〕 A 〔2〕 AC

《刑法主客一体班》

2026 方鹏刑法《主客一体班》

网络直播课程计划

cctalk“刑法学人方鹏”

报客观送主观，报主观送客观

客观主观一起学、一次过

阶段	课程		课时	时间 适时加课	课程简介	课程资料	
带读课：（基础阶段）	刑法基础课		16+（晚上+周末）	2016.1.30-2016.2	1. 刑法学习方法 2. 刑法思维及案件推理 3. 犯罪构成理论及实用 4. 总则考点 5. 核心罪名	私房讲义、教材：《方鹏讲刑法》-通用教材	
专题突破：（强化阶段）	《客观考点精析》		50+（每周一晚）	2026.2-7	疑难必考点各个击破（专题小灶班），讲全讲透；提炼、串讲、巩固高频考点 1. 分则全部罪名专题 2. 总则疑难必考点回顾 3. 刑罚论 4. 历年真题（分考点）	私房讲义、教材：《客观金题解析》、《主观一本通》	
	《主观专题与写作训练》				讲解、现场演示、习题演练、作业批改；记住套路、模板、关键词与采分点： 1. 答题方法论 2. 主观专题专讲专练 3. 主观题多观点题型 4. 主观题历年真题		
串讲、题海、考前急救包：（实战阶段+冲刺阶段+考前黄金预测）	客观	1. 考点串讲+经典真题	6+	2026.8	刑法 80 个考点全面串讲、回顾+经典真题示例	私房讲义	
		2. 重点法条带读	6+		重点法条专讲		
		3. 刑法客观金题 300 道	12+（周末）		高质量、大难度金题，畅游题海淬炼实力；黄金考点（道道经典，题题精选）		
		4. 背多分+押题 100 道	14+（七个早晚）		专项带背带练、大面积押中，物超所值		
		5. 客观考前三小时	3+（一晚）	2026.9	三小时浓缩精华（黄金考点预测）		
	主观	1. 主观题法条带读	6+	2026.8-10	重点法条专讲		
		2. 案例分析指导书精讲	3+		综合解题能力训练		
		3. 主观两天速成	8+		必考知识点回顾	《主观一本通》	
		4. 综合大案例训练+多观点题汇总	6+		道道经典：高质量、大难度、综合题全面演练		
		5. 主观背多分	14+（七个早晚）		带写带练、题题珠矶：大面积押中，物超所值	私房讲义	
		6. 主观考前三小时	3+（一晚）	2026.10	三小时浓缩精华（必考考点锦囊）		

学好真刑法，仗剑走天涯



cctalk“刑法学人方鹏”

